

臺灣暫時性移工制度是否違反 國家消除強迫勞動之人權義務？^{*} ——以不自由勞動概念檢視國際及本土實踐

楊雅雯^{**}

摘要

本文以國際勞工組織（ILO）的第29號強迫勞動公約（C29）之實踐，檢視臺灣移工制度是否涉及國家消除強迫勞動義務之違反。此問題極具重要性，因為帶有強迫勞動風險的移工制度，將使自認合法運用移工勞力的雇主，成為強迫勞動與人口販運的一環，導致系統性的人權侵害，並為供應鏈招來受他國制裁的風險。本文首先指出，臺灣即便非ILO成員國，ILO C29對臺灣仍有規範意

* 投稿日：2024年3月27日；接受刊登日：2024年8月19日。〔責任校對：鄭竣能〕。

本文初稿曾發表於2023年12月5日之中央研究院法律學研究所個人學術研討會，筆者感謝台灣國際勞工協會吳靜如慷慨擔任與談，並承蒙王必芳、陳俊翰、謝季珍、張永健、馮聖晏等諸位老師及與會先進，於會中及會後提問與交換意見。其中陳俊翰博士詢問筆者為何不認同ILO公約作為習慣國際法的主張，俊翰媽媽謝季珍女士則提醒筆者對於障礙者家庭的困境亦應有更多著墨，筆者均銘記在心。願俊翰博士對臺灣人權實踐的投入與信念，在天上繼續照亮我們的前路。

本文之完成係受國家科學及技術委員會研究計畫〈國際勞動權之人權化如何影響社會經濟人權之可司法性並邁向內國法化？〉（NSTC 112-2410-H001-006-MY2）之資助，研究助理張德志、魏立茜、林靖蓉協助資料收集與整理，同仁李孟哲協助文獻格式之統整，司法院刑事廳蔡宗廷先生協助借閱資料。筆者由衷致上謝忱。亦感謝編輯葉欣怡、陳婉瑜和責任校對鄭竣能、陳沐恩及新學林編輯羅映婷的專業與備極辛勞。

** 中央研究院法律學研究所助研究員。

穩定網址：<https://publication.ias.sinica.edu.tw/03115152.pdf>。



義，因ILO採勞動權人權化策略，且C29經聯合國人權公約條約機構交互援引，其已構成臺灣在人權公約下整體國家人權義務的一環。其次，本文提出對不自由勞動的二種理解：「意願模式」與「能力模式」，作為分析C29發展軌跡的架構。意願模式側重保護自願性免於非經濟因素的扭曲；能力模式強調自由勞動需要降低經濟脆弱處境的制度作為。本文指出ILO對強迫勞動的定義看似固守意願模式，但就消除強迫勞動的應對措施已擴展至能力模式。最後，臺灣移工制度，從意願模式觀之，係處罰規範不足、過度剝奪轉職自由；從能力模式觀之，則無力應對移工高額仲介費用的經濟危脆處境，並坐視勞動法令樓地板的缺席。臺灣政府傾向以意願模式的邏輯，回應能力模式下的訴求，移工面臨法令構築之強迫勞動風險，反映的是臺灣對不自由勞動理解的落差。

關鍵詞：強迫勞動、不自由勞動、人口販運、現代奴隸、移工、國際勞工組織、第29號強迫勞動公約、勞動權、債務約束、能力取徑。

目 次

壹、問題與背景	三、ILO走向能力模式的軌跡
貳、ILO強迫勞動公約對臺灣之規範意義	四、小結：ILO實踐作為能力模式的共識
一、為何討論ILO公約之實踐？	肆、臺灣移工制度的強迫勞動風險
二、人權體系整合詮釋的進路	一、臺灣在意願模式下的作為與欠缺
參、強迫勞動的概念與消除義務：從意願模式到能力模式	二、臺灣在能力模式下的作為與欠缺
一、「不自由勞動」的二種理解	伍、結論
二、ILO以意願模式為基底的概念與實踐	

壹、問題與背景

臺灣的暫時性跨國移工制度，是國家背書的強迫勞動制度嗎？這個問題乍看挑釁，卻有迫切的實務重要性：一個帶有強迫勞動嫌疑的移工制度，會使得仰賴這套制度提供勞動力的所有企業與個人，都進入強迫勞動的產品供應鏈中、或者獲益於強迫勞動得來的勞務，同時構成以剝削勞力為目的的人口販運，形成系統性的人權侵害。本文因此探究臺灣移工制度，是否有悖於國際勞工組織（International Labour Organization, ILO）1930年第29號《強迫勞動公約》（下稱C29或強迫勞動公約）¹之國家義務範圍，並主張臺灣移工制度提高移工遭到強迫勞動的風險。

本文提問的背景，是勞動部對消除強迫勞動之國家作為的「自我感覺良好」。2020年34個跨國非政府組織（Non-Governmental Organizations, NGOs）聯合發表聲明²，針對受聘於臺灣漁業的外籍漁工處境，訴求臺灣政府與企業採取行動終結強迫勞動，要求「政府應該確保所有漁工可以享受到國際勞工組織所提倡的核心勞工標準，包括免於強迫勞動」；「政府應該採納並實踐ILO八大核心公約」³。但就實踐ILO核心勞動標準的訴求，勞動部則主張臺灣目前

1 ILO Convention Concerning Forced or Compulsory Labour, art. 2, ¶ 1, June 28, 1930, 39 U.N.T.S. 55 (entered into force May 1, 1932). 如未特別說明，本文C29中譯採勞動部譯本：行政院勞工委員會，國際勞工公約，頁83，2010年6月，https://www.mol.gov.tw/media/hg4ezruo/國際勞工公約_第1號至第187號-中譯.pdf?mediaDL=true [<https://perma.cc/CF6U-D9FW/>]。

perma.cc係由哈佛大學圖書館所提供的學術網路資源存檔服務，存檔後之網頁資料永久保存，並提供穩定URL連結。本文引用之中文網頁均已存檔於perma.cc，故除原始網址外，亦標示存檔連結。

2 台灣人權促進會等，【聯合聲明】全球34個NGO呼籲改善臺灣遠洋漁業的人權問題，2020年11月19日，<https://www.tahr.org.tw/news/2824> [<https://perma.cc/ZUL8-ATDB>]。（作者按：此一perma.cc存檔無法直接顯示，請參考原始網址，或下載檢視。）

3 在2020年NGOs作出聯合聲明時，ILO僅有8個核心公約，但截至2023年12月，ILO核心文件則有11份，包含10個核心公約，及2014年強迫勞動公約議定書。

的勞動法令已經採納ILO所有核心公約，亦即勞動基準法、職業安全衛生法、性別工作平等法（按：已更名為性別平等工作法）、勞動三法與就業服務法，已充分履踐包括消除強迫勞動在內的核心公約要求⁴。

然而，消除強迫勞動作為國際人權體系的核心內容，若從1930年ILO C29起算，已是將近一世紀的頑強之戰。即便經長久國際努力，2022年ILO發布的全球現代奴隸（modern slavery）評估報告，仍顯示私經濟強迫勞動的驚人規模，移工亦成為當代強迫勞動議題的焦點：據其估計2021年全球約有2,760萬人遭遇強迫勞動⁵，其中

10個核心公約分別指落實結社自由和團體協商的C87與C98、落實消除強迫勞動的C29與C105、落實反就業歧視的C100與C111、落實消除童工的C138與C182，與2022年6月所新增之職業安全衛生標準的C155與C187。International Labour Organization [hereinafter ILO], ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and Its Follow-up: Adopted at the 86th Session of the International Labour Conference (1998) and Amended at the 110th Session (2022), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/normativeinstrument/wcms_716594.pdf.

- 4 勞動部2021年6月22日勞動發管字第110509873號函，轉引自陳菊、王幼玲、王美玉、紀惠容，海上人權路，頁112（2022年）。

學界亦有類似看法，如焦興鎧教授在評論我國對ILO核心公約的實踐時，主張：「一般而言，自勞動基準法實施後，我國在童工及強制性勞動之禁止兩方面，應已無太多問題」。焦興鎧，國際勞動法之演進及最新發展趨勢，全國律師，13卷2期，頁20（2009年）；焦興鎧，國際勞動法之建構及發展，勞資關係論叢，19卷2期，頁33（2017年）（以下簡稱：焦興鎧，國際勞動法之建構及發展）。

勞動部的回應隱含其無意進一步採聯合國人權公約模式內國法化ILO核心公約與移工相關公約，並進行定期審查。另一方面，行政院透過臺灣企業與人權國家行動計畫則指出《聯合國工商企業與人權指導原則》（United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights）對於國家保護義務的指引包括「推行保護人權之相關國際準則，例如：承諾促進國際勞工組織……『工作中基本原則和權利宣言』」。而臺灣政府已採取的行動包括「鼓勵企業從事負責任的企業行為，並採行國際公認之企業社會責任準則，例如……國際勞工組織各號公約」。上開宣示立場頗為模糊，是否表示行政院將責成勞動部以內國法化模式引進ILO核心公約，仍有待觀察。行政院，臺灣企業與人權國家行動計畫，頁4、9，2020年，https://investtaiwan.nat.gov.tw/bhr/zh-tw/index.php?route=catalog/taiwan_plan [<https://perma.cc/CP4S-EMFD>]。

- 5 ILO, WALK FREE & INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION, GLOBAL

86%（約2,360萬人）屬私經濟強迫勞動⁶，2022年強迫勞動受害人數與2016年所推估的2,490萬人相比，呈增長趨勢，且幾乎所有的增加都來自私經濟部門⁷。或許與大眾印象相左，超過半數的強迫勞動發生在中上所得或高所得的國家⁸。強迫勞動可能發生在任何產業，但建築、農業、漁業、家戶照顧等產業則更常見⁹——而這些正是臺灣開放暫時性跨國移工的產業。同時，跨國移工暴露在更高的強迫勞動風險下：私經濟部門強迫勞動的盛行率，移工（14人/每千人）是非移工（4.1人/每千人）的3倍以上¹⁰。

若按勞動部的回應，臺灣彷彿自外於全球強迫勞動頑疾的樂土，政府已沒有什麼任務要做。本文乃從法律制度面，聚焦在跨境移工制度，分析在ILO C29的實踐下，國家消除強迫勞動之應有作為，及臺灣移工制度是否有所落差，以檢驗勞動部官方立場是否可信。

ILO C29對強迫勞動的理解與消除之作為為何？在ILO的漫長軌跡裡可以觀察到不同的潛流。本文提出不自由勞動（unfree labour）概念的2種理解：「意願模式」與「能力模式」作為理論架構，以辨識ILO實踐背後的價值觀點與變遷，以及臺灣實務的落差。意願模式關注保護個人自願性免受非經濟因素之強制或扭曲；能力模式則進一步關注經濟危脆處境所帶來的不自由。本文透過對ILO實務文件的分析與歸納（資料範圍詳下），指出ILO對強迫勞動的概念雖然看似謹守「意願模式」的理解，但其應對措施，受人口

ESTIMATES OF MODERN SLAVERY: FORCED LABOUR AND FORCED MARRIAGE 26 (2022). 此處數據包含性產業，不過限於題旨，本文不討論性產業強迫勞動或性剝削議題。

⁶ *Id.* at 25.

⁷ *Id.* at 26.

⁸ *Id.* at 28.

⁹ *Id.* at 32.

¹⁰ *Id.* at 36.

販運預防的影響，逐漸擴至「能力模式」，強調避免剝削勞動條件與回應經濟脆弱處境的制度性積極作為。

臺灣之暫時性跨國藍領移工制度，係以獲致彈性補充勞力為目標，有強化不自由勞動之制度傾向，因而與消除強迫勞動的國家人權義務間，存在張力。然而臺灣政府面對強迫勞動的疑慮或指控，傾向以意願模式下對自由勞動的狹義理解辯護之。例如以個人契約自由為由，辯護移工未受經濟強迫、勞動法令雖缺席仍不妨礙移工受有契約保護之權利等等。惟即便僅從意願模式下ILO C29之最低標準檢視，臺灣長久以來強迫勞動處罰規範不足，並仍過度剝奪轉職自由。若進一步從能力模式相關實踐來驗證，臺灣不僅坐視法定勞動標準之覆蓋不足，並且並放任移工的債務約束處境導致的強迫勞動風險。

關於本文之研究範圍與取材，有3點說明。第一，本文從ILO C29切入，材料上包括ILO大會相關決議與授權ILO內部機關訂定的相關原則、2018年至2023年ILO專家委員會（Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations）對各國適用強迫勞動公約報告之回應¹¹、ILO對強迫勞動之一般調查（general survey）¹²、ILO為政府、企業與第一線實務工作所編寫的各式手冊與報告、強迫勞動指標、全球奴隸調查。又本文聚焦C29，但ILO處理強迫勞動的核心公約除C29外，尚有第105號《廢除強迫勞動公約》（Convention concerning the Abolition of Forced Labour）（詳下

11 ILO專家委員會負責審視成員國公約、議定書等執行之定期報告。核心公約的報告週期是3年，非核心公約的報告週期是6年。本文乃選擇由寫作當年起回溯6年的報告。

12 一般性調查係由ILO專家委員會針對特定主題，依各國定期報告，全面調查公約適用進展（無論成員國是否批准都在調查之列），其中亦包含委員會對於公約的解釋與意見，而有參考價值。截至2023年止，ILO一共針對強迫勞動禁止的第29號與第105號公約，分別在1962年、1968年、1979年與2007年做過4次一般性調查。

「貳、二、(一)」與《1930年強迫勞動公約之議定書》(Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930)(詳下「參、三、(二)、2.」)。然因專家委員會對消除私人間強迫勞動的審查，在年度報告中主要在C29項目下進行，是以本文對後二者僅於論述必要時說明。又ILO實踐軌跡豐富，但讀者可能質疑，臺灣並非ILO成員國，究竟C29對臺灣有何規範意義？就此一前提議題，下文將先指出，在人權公約內國法化與人權體系整合詮釋的進路下，C29應構成臺灣人權義務之一環。

第二，本文的關懷是私人間的強迫勞動及國家應對的義務，因此國家公權力對人民之強迫勞動雖亦為C29所涵蓋，但本文並不觸及¹³。再者，本文重心在制度問題，較不討論個別雇主或仲介的何種行為會構成強迫勞動，而是法令是否、及如何構成或升高強迫勞動風險，特別是合法移工的風險。這反映本文的出發點：強迫勞動並非「非法外勞」處於法外空間所特別面對的風險，而往往是「合法」制度所容任的脆弱處境¹⁴。

第三，本文對臺灣暫時性跨國移工制度的檢視，限於藍領移工，不包括中階及高階移工¹⁵。下文所稱「移工」，除非特別說

13 這絕非指國家權力之強迫勞動在臺灣已不重要。反之，仍待更多研究投入，如監獄低劣勞動條件，會同時涉及是否強迫勞動與酷刑禁止，參2023年8月11日臺灣花蓮地方法院112年度監簡更一字第3號判決；不得罷工的行業或過度的罷工限制可能同時構成強迫勞動與結社自由的侵害；交付替代役不符法定勤務之任務，會引發是否仍屬強迫勞動之正當例外的疑義，參內政部2002年1月15日台(90)內役字第9078792號函。

14 Hila Shamir, *The Paradox of "Legality": Temporary Migrant Worker Programs and Vulnerability to Trafficking*, in REVISITING THE LAW AND GOVERNANCE OF TRAFFICKING, FORCED LABOR AND MODERN SLAVERY 471, 476 (Prabha Kotiswaran ed., 2017).

15 亦即依就業服務法第46條第1項第8款至第10款，及外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準第3條至第5條規定所引進的移工。
就業服務法同條項第11款、及上開審查標準第6條所聘用之外國人不在本文範圍中。這個類別是專案核定及中階技術工作，其雖仍受控於國境管理體制，但

明，均僅指研究範圍內之移工（即「從事就業服務法第46條第1項第8款至第10款規定工作之外國人」）。文中所稱「臺灣暫時性跨國移工『制度』」，係指規範、管制與保護藍領移工跨境流動過程與勞動環境的法律與命令。在本文第肆部分，則將具體討論仲介管理、移工轉職限制、與移工勞動保護事項，是否有違國家消除私人間強迫勞動的人權義務。

本文係在嚴肅看待人權法內國化之國家人權義務的前提下，探究ILO核心公約的繼受、解釋和適用，並嘗試對強迫勞動國際規範，提出具理論縱深的理解。本文不在重申臺灣移工制度迭經論者指摘的沉痾，而是更欲指出，臺灣實踐與ILO強迫勞動公約軌跡的差距，反映的是對何謂「自由勞動」與如何維持自由的不同理解。如果我們只將強迫勞動視為少數惡劣雇主的例外犯行，便易於接受國家消除強迫勞動的作為只須處罰違犯了事。但ILO實踐軌跡的啟發卻是，「不受強迫」若真有意義，則勞工在勞動市場中須享有質、量兼具的一定範圍的選項，而自由的條件需要法律的支持。由此觀點，認真對待消除強迫勞動的國家人權義務，將對臺灣移工制度有全面深遠的影響。

以下行文，第貳部分除作為公約發展背景的說明外，亦藉此主張ILO C29應構成臺灣整體人權義務之一環；第參部分藉2種理解不自由勞動的模式：意願與能力，分析ILO C29對強迫勞動的理解與實踐軌跡；第肆部分轉向臺灣移工制度，分析意願模式與能力模式觀點下的欠缺。

有居留途徑，與暫時性移工有別。關於就業服務法中階技術工作移工居留，參照勞動部，留用外國中階技術人力計畫（修正本），頁23，2022年3月，<https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/download-file/2c95efb3806409ae018064f438de01c3.pdf> [<https://perma.cc/KU5W-6WUS>]。

貳、ILO強迫勞動公約對臺灣之規範意義

一、為何討論ILO公約之實踐？¹⁶

在討論ILO強迫勞動公約的實踐前，首先會遇到的質疑是，當臺灣遭排除在ILO運作外，無從成為成員國，我們何須關注ILO公約的實踐？的確，無會籍的事實，深遠影響許多論者就ILO公約對臺灣規範意義的看法。焦興鎧教授——最具代表性的ILO法學者之一，即認為因臺灣非成員國，故所有ILO公約理論上均不拘束臺灣¹⁷，原經中華民國（ROC）政府曾批准之公約於退出聯合國時失效¹⁸。但因自願遵守ILO公約，有助臺灣人權形象，故宜遵行¹⁹。

然而，對不滿足於ILO公約「僅供參考」之學者，文獻上有二種策略進一步思考關注ILO實踐的意義²⁰。一是主張ROC政府在ILO成員國期間曾完成批准的ILO公約不因退出ILO而失效，臺灣仍受曾批准之公約拘束；這也是臺灣實務上對聯合國消除一切種族歧視

16 筆者亦於另文討論ILO公約對臺灣的規範意義：楊雅雯，台灣有遵守國際勞工組織核心公約之人權義務嗎？：整全人權法詮釋取徑之芻議，台灣人權學刊，7卷4期，頁7-13（2024年）。其亦以NGO呼籲改善臺灣遠洋漁業人權（詳本文註2與相關內文）為引，討論人權法整全詮釋取徑下ILO公約對臺灣的規範意義，但2024年論文側重於整理臺灣內國法化的UN人權公約對ILO公約的援引，而本文此小節則專注在C29與UN人權公約的關連。

17 焦興鎧，全球化與基本勞動人權之保障，理論與政策，17卷3期，頁89（2004年）。相同見解：焦興鎧，國際勞動法之建構及發展（註4），頁33。

18 焦興鎧，國際勞工組織建構核心國際勞動基準之努力及對我國之啟示，台灣勞工季刊，58期，頁8（2019年）。

19 焦興鎧，工作平等國際勞動基準之建構，中華國際法與超國界法評論，3卷2期，頁412（2007年）。

20 除本文所提二種策略外，另有論者著眼於大法官對ILO公約的援引，指示立法者參酌立法，往後將構成司法審查基準之一，因而間接拘束立法，以此說明ILO公約的規範意義，如郭明政，社會法治國的司法建構——第六屆大法官會議有關社會安全法制解釋之分析，憲政時代，33卷2期，頁203（2007年）；李建良，論國際條約的國內法效力與法位階定序——國際條約與憲法解釋之關係的基礎課題，收於：廖福特編，憲法解釋之理論與實務第八輯（上冊），頁189（2014年）。惟此一進路取決於司法審查論理，本文不擬深論。

公約(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)的處理方式²¹。然而,此說首先面臨來自臺灣特殊地位的挑戰:民主化後之臺灣政府,與曾代表中國參與ILO並批准公約之ROC政府,是否同一,不無爭議。故其出發點雖是為敦促政府遵循曾承諾的人權義務,但卻有無必要地陷入中國代表權之爭的危險²²。即便擱置上開爭議,此說面對私人強迫勞動議題亦有明顯侷限,因為處於分析核心的C29未經批准,徒呼負負。

二是主張ILO公約具有條約法以外的法源性質,例如劉士豪與羅國應教授主張ILO「公約與建議書某程度已成為國際習慣法」²³,或徐揮彥教授主張ILO核心公約屬強行法(*jus cogens*)²⁴,故其主張無論臺灣有無會籍、批准與否,均受拘束。此二說在範圍上雖失之寬泛²⁵,不過至少就「禁止強迫勞動」,確有理據認為其屬習慣國際法²⁶,而C29會是此習慣法的理據與參考之一。儘管如此,公

21 關於臺灣退出聯合國前完成批准的公約效力,參黃舒芃,國際及區域人權公約在憲法解釋中扮演的角色,臺灣民主季刊,13卷1期,頁103(2016年)(該文雖討論聯合國人權公約,但其理據和退出ILO前所批准的ILO公約應類似);此亦為筆者先前主張,楊雅雯,跨越國境的勞動平權?——論勞動權利之平等保護面對「暫時性跨國移工制度」之侷限,中研院法學期刊,28期,頁226(2021年)。

消除一切種族歧視公約,係在中華民國政府退出聯合國前曾經批准並存放(1970年11月14日批准,同年12月10日向聯合國存放批准書,1971年1月9日起生效),行政院乃基於批准(而非施行法)推動公約的國家報告審查。內政部移民署,消除一切形式種族歧視國際公約(ICERD)推動計畫,2021年10月7日, <https://www.immigration.gov.tw/media/69988/icerd推動計畫.pdf> [<https://perma.cc/Z6VM-AWHH>]。

22 黃昭元,台灣與國際人權條約,新世紀智庫論壇,4期,頁45(1998年)。

23 劉士豪、羅國應,批准「兩公約」對我國勞動法制之影響——論其與ILO公約及建議書之關係,台灣國際法季刊,7卷4期,頁14(2010年)。

24 徐揮彥,從高捷泰勞事件淺論禁止強迫勞動相關國際人權規範之內涵及落實,台灣本土法學雜誌,83期,頁84(2006年)。

25 劉士豪與羅國應教授似主張所有ILO公約與建議書都是習慣法;徐揮彥教授似主張所有核心勞動基準是強行法。均有過廣之嫌。

26 論據包括類似條文在世界人權宣言、UN與區域人權公約,各公約所受之廣泛批准與實踐,與若干內國法院之明文承認:如Unocal一案中,美國聯邦法院承

約與習慣法仍是平行的法源，內容雖有重疊，但習慣法之確切內容未必等於ILO對C29的實踐。

實則，如欲藉由一個對臺灣有拘束力的法源導入C29的內容與實踐，則透過UN人權公約導入，會比藉習慣法導入來得直接與明確。因為一來UN人權公約條約機構有意識地認知、尊重與援引C29的實踐；二來臺灣有意識地選擇立法明文化國家在UN人權公約下的義務；三來，與明文人權公約相較，內國機關與法院對於習慣國際法，可能較不易承認其在內國法秩序中的地位。是以，為適切理解UN人權公約所要求的禁止強迫勞動義務，應以人權法的整合詮釋為考量，來定位ILO C29在臺灣國內法的位置²⁷。亦即ILO C29之於UN國際人權公約，因發展上的匯流與條約機構的援引，成為理解UN人權公約下，國家負有何種消除強迫勞動之人權義務內容的必要材料。隨臺灣以立法履踐UN人權公約，意謂C29及其實踐，在用於協助詮釋UN人權公約有關消除強迫勞動之國家義務內容時，會作為臺灣內國法權威的解釋參考。在此範圍內，ILO強迫勞動禁止規範與實踐宛如透過UN人權公約「間接內國法化」。此一立場，本文稱為人權體系整合詮釋。

認禁止強迫勞動為習慣國際法，外國人得就美國公司在海外之強迫勞動犯行請求賠償。Doe v. Unocal, 395 F.3d 932, ¶¶ 44-52, 114-116 (9th Cir. 2002).

27 比較林佳和教授之立場：其主張應從憲法基本權，而非國際人權，來檢視對移工限制的規範。林佳和（計畫主持人），台灣產業移工管制與保障之比較研究，委託研究成果報告書（2022年），<https://nhrc-ws.cy.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvT2xkRmlsZS9Db250ZW50L1VwbG9hZHMvUHVibGljQXJlYS85MDMwYjZlMy02MWNmLTRiZTYtYTlzM51jNWlxZjMxMzNjZGMucGRm&n=MTEw5bm0MDgu6le654Gj55Si5qWt56e75bel566h5Yi26liH5L%2Bd6Zqc5LmL5q%2BU6LyD56CU56m2LnBkZg%3D%3D&icon=..pdf> [https://perma.cc/33R9-2RF9]。筆者與林佳和教授取徑雖異，方法上之關懷卻類似，亦即國際人權文件與實踐，需以合適方法和既有的國內法秩序整合。所不同的是，林佳和教授偏重基本權之操作，但筆者則專注在人權法如何在內國法化的前提下細密發展。

二、人權體系整合詮釋的進路

ILO公約並非理所當然是UN人權系統的一部分，C29較諸UN人權系統為早，制定之初的焦點與今日大有不同，ILO C29受到UN人權公約的參酌，是經歷了任務分工到匯流的過程。

(一) ILO C29與UN人權公約之分工（1930-1970s）

ILO是一戰結束後凡爾賽和約之產物²⁸，1919年之ILO憲章前言反映一戰後之重建構想，認為社會正義是普世永久和平的基礎，而勞動條件提升對社會正義實現刻不容緩²⁹。1930年ILO通過第29號《強迫勞動公約》，然而C29當時主要關注國家強迫個人勞動的暴行³⁰，尤其是殖民政權對於原住民的壓迫³¹。從現代人權架構而言，當時C29所處理的其實傾向公政權，而非經濟社會權議題。

從哪裡可以看出C29通過時主要關注國家暴力呢？第一是公約草擬之準備。ILO理事會（governing body）於1926年指定原住民勞工專家委員會（Committee of Experts on Native Labour）研究強迫勞動問題，並以殖民地為焦點³²。第二顯示在文字上。C29第2條第1項將強迫勞動定義為「指一切工作或勞役，得自於某種刑罰之威脅（menace of any penalty），而非出於本人自願者而言」³³，而同條第2

28 ILO, Part XIII of the Treaty of Peace of Versailles, OFFICIAL BULLETIN, VOL. 1: APRIL 1919–AUGUST 1920, at 332 (1932), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_441862.pdf.

29 Constitution of the International Labour Organization, Preamble, Apr. 1, 1919, 15 U.N.T.S. 40 (entered into force June 28, 1919).

30 Beate Andrees & Amanda Aikman, *Raising the Bar: The Adoption of New ILO Standards against Forced Labour*, in REVISITING THE LAW AND GOVERNANCE OF TRAFFICKING, FORCED LABOR AND MODERN SLAVERY 359, 360-61 (Prabha Kotiswaran ed., 2017).

31 ILO, ERADICATION OF FORCED LABOUR: GENERAL SURVEY CONCERNING THE FORCED LABOUR CONVENTION, 1930 (No. 29), AND THE ABOLITION OF FORCED LABOUR CONVENTION, 1957 (No. 105), at 5 (2007) [Hereinafter ILO, ERADICATION OF FORCED LABOUR].

32 *Id.* at 6.

33 ILO Convention Concerning Forced or Compulsory Labour art. 2.

項列出允許強迫勞動的例外，包括法定軍事義務、普通公民義務、據法院判決且在公權力監督控制下執行的強制勞役、避免緊急危難的強制勞役、輕微社會服務。這些例外，都是指國家以公權力強迫人民提供勞務的正當理由，顯示第2條主要設想的是國家加諸之強迫勞動。

第三是後續公約的走向。1957年ILO通過第105號《廢除強迫勞動公約》³⁴（下稱C105），C29僅是「管理」國家強迫勞動的暴力³⁵，雖然終極目標朝向禁絕，仍非立即廢止。但C105則強調廢除。在冷戰背景下，ILO關注以強迫勞動處罰政治異見，或殖民政權以強迫勞動作為經濟發展的手段³⁶，冀望其終結。所以C105限縮C29所允許的國家暴力例外，規定不得以強迫勞動作為政治教育手段處罰政治異議；不得用以發展經濟；不得作為勞動規訓；不得作為參與罷工的處罰；不得是種族、社會、國籍、或宗教歧視³⁷，也因此蘇聯將C105視為對其政治經濟體制的攻擊³⁸。這顯示ILO從C29至C105，對強迫勞動的任務都在控制國家暴力。第四是成員國定期報告的內容。早期有成員國在報告中主張C29對其並不適用，因為該國沒有殖民地³⁹，而專家委員會未挑戰此一說法⁴⁰，反映當時普遍將強迫勞動理解為殖民國家暴力的特殊問題。

34 ILO Convention Concerning the Abolition of Forced Labour, June 25, 1957, 320 U.N.T.S. 291 (entered into force Jan. 17, 1959).《廢除強迫勞動公約》是ILO中文版用語，勞動部譯成「廢止強迫勞工」，因與其在C29譯為「強迫勞動」不一致，本文未採。

35 C29第1條規定批准國「應於最短期間內，從事廢止各種強迫勞動。為完全廢止強迫勞動，在過渡時期，只有因公共事業，得例外的使用強迫勞動……」故雖朝向廢止，但例外仍可使用。

36 ILO, ERADICATION OF FORCED LABOUR, *supra* note 31, at 3.

37 ILO Convention Concerning the Abolition of Forced Labour art. 1.

38 Andrees & Aikman, *supra* note 30, at 361.

39 如愛爾蘭（當時為Irish Free State）於1933年對ILO的報告指出其贊同C29而批准，但C29對無殖民地的愛爾蘭並不適用。League of Nations, International Labour Conference Summary of Annual Reports under Article 408, at 445 (1933), [https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661\(1933-17\).pdf](https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(1933-17).pdf).

40 Lee Swepston, *Trafficking and Forced Labour: Filling in the Gaps with the Adoption of the Supplementary ILO Standards, 2014*, in REVISITING THE LAW AND GOVERNANCE

在這段期間，私人間的強迫勞動，延續廢奴運動的傳統，已明確被禁止⁴¹。廢奴運動可說是現代國際人權法的濫觴，19世紀漸有國際共識將奴隸視為非法，國際聯盟（League of Nations，下稱國聯）在1926年通過奴隸公約（Slavery Convention）應對⁴²，二戰後由聯合國承繼國聯的廢奴任務。因此強迫勞動與奴隸，在20世紀大多時候，被視為偏向一公一私的不同議題，各自劃歸ILO與國聯／聯合國的任務範圍⁴³。

（二）ILO C29與UN人權公約之匯流（1970年代迄今）

上述分工局面，到1970年代後開始有轉變。1980年之後，受到包括蘇聯瓦解、全球化與新自由主義崛起、UN人權系統的發展，以及殖民勢力消退⁴⁴等因素影響，ILO與UN彼此往對方的守備範圍延伸，任務因而有了更多重疊。

OF TRAFFICKING, FORCED LABOR AND MODERN SLAVERY 395, 396 (Prabha Kotiswaran ed., 2017).

41 ILO Convention Concerning Forced or Compulsory Labour arts. 4-6. 也就是說，C29並不是沒有觸及私人強迫勞動，而是在當時禁止國家強迫勞動更具爭議，所以是C29及ILO更主要的著力之處。

42 Slavery, Servitude, Forced Labour and Similar Institutions and Practices Convention of 1926 (Slavery Convention of 1926), art. 1, ¶ 1, Sept. 25, 1926, 60 L.N.T.S. 253 (entered into force Mar. 9, 1927).

43 Swepton, *supra* note 40, at 397.

44 不受強迫勞動作為人權，在二戰後並不是沒有與人權語彙合流，但1950年代更被理解為對二戰中納粹政權作為的反制。Daniel Roger Maul, *The International Labour Organization and the Struggle against Forced Labour from 1919 to the Present*, 48 LAB. HIST. 477, 483 (2007). 在冷戰期間強迫勞動禁止作為人權有所爭議，直到1970年代才較明確地為人權規範所吸納，爭議的圖像頗為複雜，但殖民體制消長是因素之一。強迫勞動爭議之一是冷戰下共產集團與資本主義國家相互指摘，共產集團被說是採用政治性強迫勞動；資本主義國家則遭指勞工處境與薪水奴隸無異。爭議之二是新獨立國家與殖民國相互指摘，某些殖民國被指為持續戰前母國與殖民地二重勞動體制的分野，但某些新獨立國家卻亦被指摘，在發展威權主義之下，仍維持殖民前的強迫勞動經濟發展體制，甚至以反殖民的大旗正當化此種經濟發展政策。故殖民政權消退有助於強迫勞動禁止進入人權系統，受到較廣泛接受。Anne-Charlotte Martineau, *Forced Labour*, in INTERNATIONAL LAW AND THE COLD WAR 271, 278-79, 281-84 (Matthew Craven, Sundhya Pahuja & Gerry Simpson eds., 2019).

申言之，在ILO方面，殖民地的逐步獨立與蘇聯瓦解，使國家強迫勞動議題重要性下降。全球化帶來更大規模的人口遷徙，私人間強迫勞動呈現不同於以往經濟生產型態的面貌，重要性上升，ILO對私人間強迫勞動關注日增⁴⁵。再者，新自由主義興起，勞動市場「去管制化」的聲浪，導致ILO這個以勞動標準為使命的組織邊緣化，ILO因此需要突圍的論述與策略，其在1998年以基本宣言正式宣告ILO的「人權化」路線，亦即以人權、權利的語彙和法律工具，去推進核心勞動標準和條件的提升，不再將自身侷限為專門設定勞動標準的國際組織，同時也是一個人權的監測與實踐機構⁴⁶。上述發展反映在ILO的報告與文件上，1970年起ILO的專家委員會報告零星關注各國私人間違反意願的勞動如奴隸與債務約束，跨出殖民地國家暴力而注意到私人間的強迫⁴⁷。比較1979年與2007年對強迫勞動的一般調查，1979年調查僅稍微提及債務質役⁴⁸（debt bondage）與其他私人間強迫勞動的型態⁴⁹，但是在2007年調查中ILO關注從傳統（農民債務質役）到現代（人口跨境流動）的強迫勞動，包括人口販運、家戶勞工、移工⁵⁰，不再侷限於國家公權力對個人的壓迫。

在UN方面，公民與政治權利國際公約（International Covenant on Civil and Political Rights，下稱公政公約）與經濟社會文化權利

⁴⁵ Andrees & Aikman, *supra* note 30, at 363.

⁴⁶ Lee Swebston, *How the ILO Embraced Human Rights*, in RESEARCH HANDBOOK ON LABOUR, BUSINESS AND HUMAN RIGHTS LAW 295, 300 (Janice Bellace & Beryl ter Haar eds., 2019).

⁴⁷ Swebston, *supra* note 40, at 398-99.

⁴⁸ 「債務質役」係依《禁止奴隸制、奴隸販賣及類似奴隸制之制度與習俗補充公約》（Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery）用語，基於人權法的脈絡，避免太快代入我國人口販運防制法上債務約束的法律定義來理解，故採債務質役。

⁴⁹ ILO, ABOLITION OF FORCED LABOUR: GENERAL SURVEY CONCERNING THE FORCED LABOUR CONVENTION, 1930 (No. 29), AND THE ABOLITION OF FORCED LABOUR CONVENTION, 1957 (No. 105), at 78 (1979).

⁵⁰ ILO, ERADICATION OF FORCED LABOUR, *supra* note 31, at 35-46.

國際公約（International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights，下稱經社文公約）於1966年通過、1976年生效。公政公約第8條規定奴隸、奴工（*servitude*）與強迫勞動之禁止，其有關強迫勞動可容許之例外的文字⁵¹，與C29第2條頗為類似，顯示C29的影響。而公政公約對免於違反意願勞動之人權，採取比較寬廣的看法，及於國家與私人的犯行⁵²，ILO與UN人權體系對違反意願勞動的守備範圍乃有重疊，相互補充。人權事務委員會（Human Rights Committee，公政公約之條約機構）從2000年起，系統性檢視各國報告書中有關強迫勞動與人口販運，而人口販運是私人強迫勞動的典型（詳下「參、三」），Lee Swepston因此指出，儘管公政公約第8條的文字與C29第2條有略微差異，但人權事務委員會的實踐，反映其「默示的理解，即便文字有細微的差異，但其範圍與標準是一致的」，二個條約機構注意到各自在處理類似問題，而對方機構的理解，對於自己所負責監管的公約，亦是恰當的⁵³。

至於經社文公約，其第6條保障「人人應有機會憑本人自由選擇或接受之工作謀生之權利」⁵⁴，文義上必然觸及強迫勞動之禁止。不過經濟、社會及文化權利委員會（Committee on Economic, Social and Cultural Rights，經社文公約之條約機構，下稱經社文委員會）過去較少討論強迫勞動，比較著重在就業歧視與失業⁵⁵。但到了2005年經社文公約第18號一般性意見，針對第6條工作權的規範內容，先引用ILO C29強迫勞動的定義後，隨即重申：「締約國需

51 International Covenant on Civil and Political Rights, art. 8, ¶ 3(C), Dec. 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171 (entered into force Mar. 23, 1976).

52 Swepston, *supra* note 40, at 397.

53 “with a tacit understanding that the coverage of their standards is virtually identical in spite of minor variations in wording”. LEE SWEPSTON, FORCED AND COMPULSORY LABOUR IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW 15 (2015), http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_342966/lang--en/index.htm.

54 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, art. 6, ¶ 1, Dec. 16, 1966, 993 U.N.T.S. 3 (entered into force Jan. 3, 1976).

55 SWEPSTON, *supra* note 53, at 14.

要按照《世界人權宣言》第四條、《禁奴公約》第五條及《公民與政治權利國際公約》第八條明確闡述的內容，廢除、禁止並打擊各種形式的強迫勞動」⁵⁶，明文將強迫勞動之禁止含納於第6條範圍。

這些條文本身或一般性意見的援引和解釋，使ILO強迫勞動的規範，匯流入公政公約與經社文公約整體的權利系統內。固然不同條約機構之偏重會有不同，但無論是國家暴力或私人間的強迫勞動，解釋上都同時是公政公約、經社文公約、和C29關注的對象。

（三）小結

UN人權公約與C29就禁止強迫勞動既然任務交疊，則就免於強迫勞動之權利，與相關的保護、預防、促進義務亦應形成整合性的詮釋理解。因為國際人權法體系雖係由多重的文件與機制所構成，但其均奠基在對人類脆弱性的理解，共同尋求所有人類尊嚴度日的可能⁵⁷。所以人權法體系內，對於同一權利內容的詮釋不應各吹各調。雖然實務上同一權利難免因有權解釋者不同，而有不同詮釋，但不破碎矛盾、整全一致的理解，仍是值得追求的規範目標⁵⁸。亦有許多制度設計與實務運作，有意識地在降低管轄衝突與法理上的破碎⁵⁹。由此角度，經社文委員會就強迫勞動援用ILO文件與實踐，不僅是在借用其專業，更是藉由尊重、認知、援用其他機構對其核心任務的解釋，來維持人權體系的內在一致性。

56 Economic and Social Council, The Right to Work: Article 6 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ¶ 9, U.N. Doc. E/C.12/GC/18 (Feb. 6, 2006).

中文為法務部譯本，法務部法制司編，公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約：一般性意見，2版，頁283（2018年）。

57 Mehrdad Payandeh, *Fragmentation within International Human Rights Law*, in A FAREWELL TO FRAGMENTATION: REASSERTION AND CONVERGENCE IN INTERNATIONAL LAW 297, 306 (Mads Andenas & Eirik Bjorge eds., 2015).

58 關於「人權體系整合詮釋」更詳細的說明，參楊雅雯（註16），頁14-15。

59 例如同一案件只能由一條約機構或法院受理，一經受理，其他機構不再有管轄。Payandeh, *supra* note 57, at 304.

綜上，ILO C29實踐對臺灣有何規範意義？在《公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法》規定，公約之適用須參考條約機構解釋，責令各級政府機關依兩公約行使職權⁶⁰，且經社文委員會援引C29為經社文公約第6條之內涵的前提下，為整合詮釋各級政府機關在經社文公約下禁止強迫勞動應有之人權作為，應將ILO對C29相關國家作為的穩定實踐與意見，視為解釋第6條相關義務內涵的權威見解，在此範圍內，C29構成臺灣人權義務的一環。

參、強迫勞動的概念與消除義務：從意願模式到能力模式

基於C29是臺灣因UN人權公約所負之人權義務的出發點，本節進入對C29實踐的觀察。以下先介紹不自由勞動的理論架構，再指出C29對不自由的理解，從「違反意願」走向「剝奪能力」的軌跡。

一、「不自由勞動」的二種理解

強迫勞動是一種「不自由勞動」(unfree labour)。不自由勞動不是法律名詞，而是政治經濟學描述人無法自由進出勞動市場，在市場上買賣、交易自身勞力的現象⁶¹，如描述前工業化的農奴經

⁶⁰ 公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法第3條及第4條。第3條規定未提及經社文委員會，迭經指出為立法疏漏，參如廖福特，法院應否及如何適用《經濟社會文化權利國際公約》，台灣人權學刊，1卷1期，頁9（2011年）；張文貞，演進中的法：一般性意見作為國際人權公約的權威解釋，台灣人權學刊，1卷2期，頁41（2012年）。

⁶¹ E.g., Tom Brass, *Some Observations on Unfree Labour, Capitalist Restructuring, and Deproletarianization*, 39 INT'L REV. SOC. HIST. 255, 256 (1994).

臺灣社會科學學者以不自由勞動概念來談移工議題者代表性的作品，參如藍佩嘉，合法的奴工，法外的自由：外籍勞工的控制與出走，台灣社會研究季刊，64期，頁107-150（2006年）；顧玉玲，跛腳的偽自由市場：檢析台灣外勞政策的三大矛盾，台灣人權學刊，2卷2期，頁93-112（2013年）。

濟、殖民地奴隸體制等生產方式，今日則一般認為包含但不限於法律界定的奴隸、類奴隸待遇、強迫勞動、人口販運等類別。不自由勞動概念本身圍繞許多辯論（以下會再觸及），它不是黑白分明的用語，而更傾向是一個問題意識：究竟哪些不自由應該被辨認出來、由誰處理；與資本主義和階級形成的關係為何；自由與不自由是否能夠二分等等。這些理論分歧，提供了有用的分析架構，可以用來定位ILO及個別國家在面對強迫勞動時的基本取徑，或說是一種理論座標。因為人們認為什麼現象會涉及「不自由」勞動，反映了其認為「自由的勞動」應該是怎麼樣的、對理想勞動市場的規範預設、以及勞動市場，究竟是一自由、自主的場域、抑或其實是宰制、剝削的場域⁶²。

本文提出「意願模式」與「能力模式」二種對不自由勞動的理解，作為界定ILO就強迫勞動的路線發展，與分析臺灣制度實踐的架構。這二種不自由勞動的立場可視為是一組政治哲學上消極自由與積極自由的對比，源於馬克思（Karl Marx）對用古典契約自由來描述薪資勞動的批判。二者對於是什麼構成「不自由」勞動的來源、什麼是國家應該負責處理的不自由，有不同的側重，也反映出其對於人的主體性有不同想像。二者最大的差異在對人受制於經濟必需（economic necessity）是否是不自由勞動的判斷與應對。須先說明的是，以下的比較與辯論不為論述哪一種模式較好或正確，而是在確立二個大立場的分野，又個別立場內部亦有方法與路線分歧，但因與論旨無關，本文亦避免涉入。

（一）意願模式

意願模式是一種古典自由主義的認識，其所認知的不自由是各種型態的直接脅迫（duress），包括物理性、身體性的強制

⁶² Judy Fudge, *Modern Slavery, Unfree Labour and the Labour Market: The Social Dynamics of Legal Characterization*, 27 SOC. & LEGAL STUD. 414, 429 (2018).

(coercion) 與干涉 (interference)，如暴力、拘禁，與心理上威嚇、懲罰，和認知上的扭曲、欺騙。意願模式所認知的不自由，原則上是非經濟性的強制，也是法律人傳統上認為會減損傷害人的意志自由的因素。亦可說，意願模式傾向關注消極自由 (negative freedom)，以柏林 (Isaiah Berlin) 所談的消極自由來說，自由即是不存在干涉 (non-interference)⁶³，因此將自由的勞動理解為締約意願不受他人的強制，國家保護自由的方式即是阻止、處罰干涉。如刑法上「強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法」(第221條)的類似規定方式，即是在典型意願模式對自由主體的想像下，所會認知的不自由與處理方式。相對地，如果不存在這些會傷害意志自由的非經濟因素，人即是自由締約主體，進入契約是個人自由的展現，而契約的執行，即是貫徹締約各方的自由意志⁶⁴。

(二) 能力模式

能力模式對意願模式有所質疑與補充，認為除了非經濟性的強制干涉會造成不自由外，也進一步考慮人必需謀生的經濟現實所造成的不自由。若說意願模式傾向關注消極自由 (不存在外力干擾)，則能力模式可說是關注積極自由，認為自由以存在合理、可實現的選項為前提條件。以沈恩 (Amartya Sen) 的「能力取徑」(capabilities approach) 下的積極自由概念來說⁶⁵，自由是衡酌一個

⁶³ ISAIAH BERLIN, LIBERTY 170 (Henry Hardy ed., 2d ed. 2002).

⁶⁴ Clare Dalton, *An Essay in the Deconstruction of Contract Doctrine*, 94 YALE L.J. 997, 1027 (1985); John P. Dawson, *Economic Duress: An Essay in Perspective*, 45 MICH. L. REV. 253, 256 (1947).

⁶⁵ capabilities approach 筆者早先用語是「能力進路」，但萬毓澤教授用「能力取徑」更貼近中文語感，故從之。萬毓澤，探尋人的本質：馬克思《巴黎手稿》、「能力取徑」與批判性社會科學，收於：何偉明編，*重讀通識經典論文集*（一）：馬克思《1844年經濟學哲學手稿》，頁69（2023年）。

「積極自由」有不同的用法，特別強調這裡不是指柏林的積極自由，即自主 (autonomy) ——做出符合真實自我意志的選擇，強調內在的本真性。沈恩的積極自由並不是在討論「成為自己主人」的內在態度。

人在內在與外在的全部限制下，有多大可能性，此人得以達成對他個人而言值得實現的事項或狀態⁶⁶，這個可能性不應該低於某個最低標準⁶⁷。國家保護自由的任務因此是提升能力⁶⁸，例如透過制度安排，使人人有內容與數量合理、且實際有可能實現的選項可供選擇⁶⁹；合理選項的基準至少是使個人具備最起碼生命繁盛的條件⁷⁰。傷害消極自由一定也會傷害到積極自由，反之則未必：受他人以非經濟手段直接強制榨取勞力，在意願與能力模式下都構成不自由勞動，但受限於經濟需求而願意接受難以維持生活最低水準的惡劣工作，在意願模式下非屬不自由勞動，但在能力模式下則可能構成不自由勞動。

對意願模式較為限縮的不自由勞動概念，最經典的批判來自馬克思，他指出工業資本主義下的薪資勞動（wage labour），勞工可以在勞動市場中自由選擇雇主締結契約，相對於前工業資本主義之封建體制中，農奴被綁在固定的土地上為固定的主人提供勞役，剝奪流動可能性，薪資勞動確實是「自由勞動」。但他隨即指出薪資勞工

66 沈恩對積極自由的界定：“...I have found it more useful to see ‘positive freedom’ as the person’s ability to do the things in question taking everything into account (including external restraints as well as internal limitations).” AMARTYA SEN, *RATIONALITY AND FREEDOM* 586 (2002).

67 Richard Arneson, *Egalitarianism*, in *THE STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY* (Edward N. Zalta ed., Summer 2013 ed. 2013), <https://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/egalitarianism/>.

68 納斯邦（Martha C. Nussbaum）的能力取徑在分配上採充足主義（sufficientarian）立場。INGRID ROBEYNS, *WELLBEING, FREEDOM AND SOCIAL JUSTICE: THE CAPABILITY APPROACH RE-EXAMINED* 101 (2017).

69 用 Philip Pettit 的分析來說，「選項自由」（option-freedom）同時牽涉到兩個面向，即選項本身的內容性質，以及通向選項的路徑是否真實存在。Philip Pettit, *Agency-Freedom and Option-Freedom*, 15 *J. THEORETICAL POL.* 387, 389, 391 (2003). 在能力模式下，自由意味著選項的內容和路徑都需要高過最低的合理標準。

70 以能力取徑術語來說，合理選項是選項須足以使個人具備得以實踐最重要功能（functions）的基本能力（basic capabilities）。John O’Neill, *Varieties of Unfreedom*, *THE UNIVERSITY OF MANCHESTER RESEARCH* 20 (2022), <https://research.manchester.ac.uk/en/publications/varieties-of-unfreedom>.

的自由，具有雙重意義，既是「不受拘束」也是「毫無支持」⁷¹：一方面勞工可以在勞動市場自由選擇雇主販賣勞動力，但另一方面，勞工亦是身無長物，不享有（**free from**）得以自足的生產工具，是以經濟需求迫使勞工必須進入勞動市場謀生⁷²——他或許能選擇將勞動力賣給誰，但他無從選擇不販賣勞動力。換言之，人的勞動仍受到「強迫」，但在資本主義自由市場下，「強迫」手段不再是暴力，而是經濟必需的驅策⁷³。

當然，能自由販賣勞力還是遠勝於不能自由販賣⁷⁴。但馬克思所批判的正是，資本主義的勞動市場所能給的「自由」也就到此為止了——這種（消極）自由是如此稀薄與形式，遠非免於剝削與宰制的真自由狀態⁷⁵，勞動契約徒有勞力流動與個人獨立的形式，但卻是一種法律虛構（**legal fiction**）⁷⁶，其表面的自願性，掩蓋勞工受制於資本家之經濟拘束；虛幻的契約自由原則，模糊掉人受到資

71 “For the transformation of money into capital, therefore, the owner of money must find the free worker available on the commodity-market; and this worker must be **free in the double sense** that as a free individual he can dispose of his labour-power as his own commodity, and that, on the other hand, he has no other commodity for sale, i.e. he is rid of them, he is free of all the objects needed for the realization [Verwirklichung] of his labour-power.” KARL MARX, CAPITAL: A CRITIQUE OF POLITICAL ECONOMY VOL. I, at 272-73 (Ben Fowkes trans., Penguin Books 1976) (1867) (**emphasis mine**).

72 Kendra Strauss, *Coerced, Forced and Unfree Labour: Geographies of Exploitation in Contemporary Labour Markets*, 6 GEOGRAPHY COMPASS 137, 139 (2012).

73 Nick Bernards, *The Global Politics of Forced Labour*, 14 GLOBALIZATIONS 944, 945 (2017).

74 AMARTYA SEN, DEVELOPMENT AS FREEDOM 7 (1999).（沈思指出馬克思對美國廢奴的評論。）

75 Jairus Banaji, *The Fictions of Free Labour: Contract, Coercion, and So-Called Unfree Labour*, 11(3) HIST. MATERIALISM 69, 91 (2003).

76 “The Roman slave was held by chains; the wage-labourer is bound to his owner by invisible threads. The appearance of independence is maintained by a constant change in the person of the individual employer, and by the legal fiction of a contract.” MARX, *supra* note 71, at 791.

本經濟壓迫的經驗⁷⁷。有些受馬克思影響的論者因此認為真正的自由勞動，必須掙脫資本主義的生產模式，如Jairus Banaji所言，受到（經濟）壓迫之人，所享有的真正自由是反抗的權力，無論是獨自或透過群體，去成為一個在世界中行動的人⁷⁸。

讀者未必要全面接受馬克思有關薪資勞動必然受迫於資本的政治經濟分析，或興起終結資本主義的雄心，才能接受能力模式的洞見：赤貧的生命往往是沒有選擇的生命⁷⁹。經濟危脆在客觀上會壓縮人的選項，當人「受迫於所需」（*compelled by necessity*）⁸⁰，選項極度匱乏，人是不自由的。相較之下，意願模式側重在個人做選擇時，其意志有沒有受到非經濟的外力干擾。即使選項很少、很糟，人仍不乏主動性，仍盡可能在僅餘空間中做相對不糟的選擇，這種主動，在意願模式下足以稱為自由勞動，但是當選項糟糕到一定程度，能力模式會認為堪稱自由選擇勞動的客觀條件並不存在，已是不自由勞動。例如在貧困中為了支應醫療急需乃以未來的勞務作為擔保而借款，其工作條件艱困危險且收入微薄，但在還清借款之前無法離開這份工作，這可能構成債務約束，在能力模式是受迫於經濟需求的不自由勞動，但在意願模式則透過契約展現了自由。

能力模式對於意願模式裡古典個人自由預設的批判，所帶來的啟發是，勞動市場中的自由勞動，內在即帶有「選擇」與「無選擇」的兩面性；始終存在自由（選擇賣誰）與不自由（被迫販賣）之間的張力。在此張力中，有些不自由被承認是問題需要處理，有些不自由則被略過，當作自然如此的狀態⁸¹。勞動市場的自由的兩面性，很適切地說明許多看似矛盾的現象：何以失業既是抵制惡劣

⁷⁷ Banaji, *supra* note 75, at 91.

⁷⁸ *Id.*

⁷⁹ O'Neill, *supra* note 70, at 21.

⁸⁰ *Id.* at 20.

⁸¹ Strauss, *supra* note 72, at 139.

雇主的最後出口，也可能是導致生計壓力的懲罰；何以長時間加班既可能是勞工歡迎、使工作更有價值的特性⁸²，也是受到強迫的惡劣工作條件的指標⁸³；何以雇主提供的指定住宿既被包裝為福利或實質所得⁸⁴，卻也是增加孤立與受監視狀態的因素⁸⁵，從而增加強迫風險。

(三) 比較與評估：4項取徑差異

意願與能力模式對不自由勞動的不同理解，隨之導致幾個取徑上的差異。第一個差異在於剝削和不自由勞動的關係。剝削指不公正之利益掠奪，尤其趁人之危的利益掠奪⁸⁶。對意願模式來說，不正利益之奪取與自願性的違反是分開的課題，剝削可能違反被剝削者意願，卻也可能符合其意願，如Johannes Koettl將剝削分成「合意剝削」(consensual exploitation)與「非合意剝削」(nonconsensual exploitation)，非合意的剝削包括人口販運、強迫勞動與奴隸等型態，違犯者以不法手段強制勞工進入與接受惡劣的條件，他認為是刑法要制裁的犯罪。而合意剝削則是因為被剝削者欠缺其他經濟資源與謀生管道，雇主享有買方壟斷(monopsonistic)的市場力量，壓低勞工薪資與工作條件，他認為屬勞動法所應處理的勞動條件提

82 根據藍佩嘉、簡永達的研究，在越南移工的案例中，宣稱高度加班的工作，在臺移工會多付出新臺幣15,000元以上的買工費，新引進的海外移工則會多付500至1,500美元的仲介費。藍佩嘉、簡永達，越南牛頭與台灣仲介：跨國招工網絡的彈性重組，台灣社會學，43期，頁19、31、41（2022年）。

83 參以下「參、三」有關人口販運與強迫勞動指標。

84 如菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處勞工中心所提供的契約範本要求雇主提供住宿，但另一方面也規定移工不得外宿。馬尼拉經濟文化辦事處勞工中心（Manila Economic and Cultural Office, Labor Center），Employment Contract for Factory Workers/Construction Workers 廠工/營造業勞動契約(LBR 03-C-IW)，第5條，<https://www.meco-labor.org.tw/download.php>（最後瀏覽日：2024年2月5日）。

85 Shamir, *supra* note 14, at 483.

86 Matt Zwolinski, Benjamin Ferguson & Alan Wertheimer, *Exploitation*, in THE STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY (Edward N. Zalta & Uri Nodelman eds., Winter 2022 ed. 2022), <https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/exploitation/>.

升議題⁸⁷。Koettl的分類即一適例，顯示在意願模式下，剝削通常被認為涉及勞動條件與所得分配，和以不法手段影響意願的問題，不僅概念上可分，且「自願」接受剝削，只是勞動條件低劣不公，通常也不像違反意願的剝削，那般嚴重惡劣：沒了一份條件惡劣工作或或許逃過被剝削，但勞工可能只覺得生計無著情況更慘⁸⁸，還不如如有份「合意剝削」的工作。

相對地，對能力模式而言，剝削與不自由在現象與概念上有重疊之處，因為其既認為受迫於經濟必需可能造成不自由勞動，因此即使合意剝削，仍可能因為受剝削者的意願來自欠缺合理選項，而構成不自由勞動。而且剝削本身也可以是一種經濟強迫的手段，因為對於經濟危脆之人的掠奪，如低薪，會使其更難從危脆處境中脫身，不斷窮忙，加劇其受迫於經濟必需的惡性循環。此外，對能力模式來說，何謂剝削與不自由勞動，都取決於某些社會正義理論，因為剝削指獲取不公正的利益，不自由勞動包括不具備能滿足最基本需求的合理選項下所為之勞動，無論是「公正」或「合理」的基準線，往往來自於對於人的哪種脆弱處境不應被利用，方屬公正合理的背景認知。

第二個差異在於二者對不自由勞動的不同理解，影響對解方何在的看法。意願模式傾向於將國家之於不自由勞動的角色認為是中性的、乃至於是良善的⁸⁹，不會批判法律將人必須出賣勞力才能存

87 Johannes Koettl, *Human Trafficking, Modern Day Slavery, and Economic Exploitation* 7-8 (Soc. Protection Discussion Papers, Paper No. 0911, 2009), <https://documents1.worldbank.org/curated/en/208471468174880847/pdf/498020NW0SP0d10Box341969B01PUBLIC1.pdf>.

88 Jonathan Wolff, *Structures of Exploitation*, in *PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF LABOUR LAW* 175, 175 (Hugh Collins, Gillian Lester & Virginia Mantouvalou eds., 2018).

89 Genevieve LeBaron, *Unfree Labour Beyond Binaries: Insecurity, Social Hierarchy and Labour Market Restructuring*, 17 INT'L FEMINIST J. POL. 1, 2 (2015).

活的經濟現實予以制度化⁹⁰，而這正是能力模式所欲修正的。意願模式也傾向於將不自由勞動視為資本主義自由市場的偏差⁹¹，是少數人的犯行扭曲了本應自由的市場參與，因而重在處罰遏止脅迫行為，除去干擾市場的因素。但能力模式論者常指出不自由勞動實則往往是所謂自由的勞動市場的產物⁹²，本身就鑲嵌在勞動市場中，有制度面、法律面的成因，不是個人非法行為下的特例⁹³，所以不自由勞動的消除，必然涉及制度性的調整⁹⁴。例如一個高度彈性化、取消勞動安全與最低條件規定的勞動市場，對於遵循古典自由的意願模式來說，從雙方可以任意締約解約與形塑契約內容的角度，是高度自由的，但從能力模式而言，則是加深勞方的危殆處境與對雇主的經濟依賴，降低就業選項的品質，從而增加不自由勞動的風險。

第三個差異是關於自由與不自由的分野。能力模式通常強調不自由勞動的判定是建構的，也是政治的，應避免將自由與不自由勞動認為是自然、明確且截然二分的兩極⁹⁵，因為從最惡劣的剝削情境到尊嚴勞動之間有無數來源不同、程度不等的不自由⁹⁶，而對自

90 Fudge, *supra* note 62, at 417.

91 *Id.* at 418.

92 不自由勞動與工業化資本主義生產模式的關連，是馬派學者對不自由勞動的核心辯論；馬克思認為資本主義的特色之一就是自由勞動力，那麼如何解釋在資本主義體制下所見到的不自由勞動？See, e.g., TOM BRASS, TOWARDS A COMPARATIVE POLITICAL ECONOMY OF UNFREE LABOUR: CASE STUDIES AND DEBATES (1999); J. Mohan Rao, *Freedom, Equality, Property and Bentham: The Debate over Unfree Labour*, 27(1) J. PEASANT STUD. 97 (1999). 本文無意涉入此辯論，對法律學者重要的毋寧是不自由勞動不是個別零星現象，而有法律制度面的支持。

93 Jens Lerche, *A Global Alliance Against Forced Labour? Unfree Labour, Neo-Liberal Globalization and the International Labour Organization*, 7 J. AGRARIAN CHANGE 425, 431 (2007).

94 Fudge, *supra* note 62, at 415.

95 Julia O'Connell Davidson, *New Slavery, Old Binaries: Human Trafficking and the Borders of 'Freedom'*, 10 GLOB. NETWORKS 244, 245 (2010).

96 KLARA SKRIVANKOVA, BETWEEN DECENT WORK AND FORCED LABOUR: EXAMINING

願與強迫的分野，實則是取決於道德與政治判斷，認定哪些讓人留在工作上的壓力是正當的⁹⁷。相對地，意願模式區分非經濟性與經濟性因素，經濟性「強迫」不算不自由，等於是自願的、同意的，而當事人的同意，即為背後的經濟秩序與契約安排提供了正當性。意願模式因此被能力模式論者批評是過度人工的二分法⁹⁸，且在界定不自由勞動的同時，正當化不自由「以外」的狀態⁹⁹，一概視為自由，忽視不自由勞動的建構性與政治掙扎。例如藉著認定法律定義下的強迫勞動與販運是不自由，而忽視在法律定義涵蓋外的不平等僱傭關係裡，亦有類似的剝削與壓力，以及法律在延續、強化這些不自由狀態的角色¹⁰⁰。

最後，二者之實踐是否仰賴社會正義共識亦有不同。能力模式雖然提供比意願模式更敏感、更寬的不自由勞動辨識度，但這卻也是其弱點。意願模式所認定的不自由相對清晰、有共識，解方也直接、可操作。能力模式指出勞動市場的侷限與法律制度的不中性，但這卻不足以具體指向人究竟應該享有什麼樣的選項才稱得上是自由的勞動。如前指出，它需要結合另外的社會正義理論來劃定自由的基準線。例如想買豪宅名車而「不得不」在收入豐厚但極為苛求表現的企業任職，不算是受迫於經濟必需的不自由勞動，這個結論仰賴若干關於社會分配正義的判斷才能得出。可是如果對於社會正義概念觀持有合理歧見之眾人，對基準線難有共識，那麼在能力模式下辨識不自由勞動，亦成困難任務。這呼應了前述何謂不自由的

THE CONTINUUM OF EXPLOITATION 4 (2010), <https://resourcecentre.savethechildren.net/document/between-decent-work-and-forced-labour-examining-continuum-exploitation/>.

97 Robert Steinfeld, *Coercion/Consent in Labour* (Centre on Migration, Pol'y and Soc., Working Paper No. 66, 2009), https://www.compas.ox.ac.uk/2009/wp-2009-066-steinfeld_coercion_consent_labour/.

98 LeBaron, *supra* note 89, at 4.

99 Davidson, *supra* note 95, at 255-56.

100 LeBaron, *supra* note 89, at 2.

認定，本身就是政治掙扎的觀點，但這同時也是在承認，通向自由的方向與路徑不易確認。下文「參、四」將會指出，能力模式下合理選項基準線界定的困難，正是ILO實踐可以有所用益之處：ILO對何謂自由勞動的條件，可以視為是共識下的具體準則，而避免糾結在抽象上位正義概念觀之歧見中。

在確立意願模式與能力模式的理論架構後，下文即用以分析ILO對強迫勞動的認定與實踐，其概念原則是意願模式的（下文「參、二」），但因應措施則有向能力模式擴展的軌跡（下文「參、三」）。

二、ILO以意願模式為基底的概念與實踐

（一）意願模式下的強迫勞動概念

1. 公約條文定義

C29第2條對強迫勞動的定義，是討論消除強迫勞動義務的起點，其規定強迫勞動指「得自於某種刑罰之威脅，而非出於本人自願」的工作¹⁰¹。亦即處於違反意願提供勞務，且在懲處或懲處之威脅下無法離開的狀態¹⁰²。當中最重要的兩個要素是「非自願性」（has not offered himself voluntarily）與「懲處之威迫」（under the menace of any penalty）。ILO專家委員會認為此二要件須同時成立。有些事實會同時滿足二個要件，既傷害自願性也構成懲處威迫¹⁰³，例如被害人遭到身體暴力脅迫而勞動，在暴力威脅下不僅人的自願蕩然無存，也構成持續的威迫，使人無法離開，但此二者仍是分開的要件，應個別判斷。

¹⁰¹ ILO Convention Concerning Forced or Compulsory Labour art. 2.

¹⁰² ILO, COMBATING FORCED LABOUR: A HANDBOOK FOR EMPLOYERS AND BUSINESS 4 (June 25, 2015), http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm.

¹⁰³ ILO, ERADICATION OF FORCED LABOUR, *supra* note 31, at 20.

不受強迫的勞動，必須是持續地自願，自願性貫穿契約的進入、持續與離開之各階段。這不只指勞工是在明確知悉契約內容的情況下同意進入勞僱契約，在工作繼續期間內也都是自願的，最重要的是勞工能隨時收回自願¹⁰⁴，離開這份工作。侵害自願性明顯的例子如施加身體暴力、行動拘束，或誤導欺騙工作之性質或條件¹⁰⁵。即便當事人是在知道工作的內容性質之下進入勞動關係，但是如果實際工作的條件和環境，比當事人所預知的惡劣甚多，仍舊會構成非自願，因為當事人仍然可能在工作條件上遭誤導¹⁰⁶。所以知悉工作性質，不代表當事人就一定不是強迫勞動及人口販運的受害人，這點在性工作中更顯重要，蓋工作條件的惡劣超過認知預期，而使得工作具有強迫性質，與當事人自願接受特定工作內容，是可分的。

至於「懲處之威迫」通常指防止當事人離開的手段。解釋上涵蓋有形無形的不利手段，除了身體直接強制，如監禁或暴力，也包括心理上的威嚇，並且威嚇不一定以有形、明確的惡害，例如恐嚇對方會遭到來自靈界的報復亦屬之。「懲處之威迫」也包括權利或利益的損失，例如扣住薪資¹⁰⁷，失去勞工手冊裡列出的利益，如升遷、轉職、找新工作、獲得物資、住屋¹⁰⁸，又或者被要求過度加班，不從則威脅將丟掉工作等¹⁰⁹。

2. 強調自願性的貫徹而非著眼經濟需要

ILO對強迫勞動的界定，以及強迫勞動公約的文字與國家任

¹⁰⁴ *Id.* at 21.

¹⁰⁵ ILO, A GLOBAL ALLIANCE AGAINST FORCED LABOUR: GLOBAL REPORT UNDER THE FOLLOW-UP TO THE ILO DECLARATION ON FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND RIGHTS AT WORK 2005 (Mar. 1, 2005). http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_081882/lang--en/index.htm [Hereinafter ILO, A GLOBAL ALLIANCE AGAINST FORCED LABOUR].

¹⁰⁶ ILO, ERADICATION OF FORCED LABOUR, *supra* note 31, at 42.

¹⁰⁷ ILO, A GLOBAL ALLIANCE AGAINST FORCED LABOUR, *supra* note 105, at 6.

¹⁰⁸ ILO, ERADICATION OF FORCED LABOUR, *supra* note 31, at 20.

¹⁰⁹ *Id.* at 71-72.

務，基本上反映意願模式對不自由勞動理解。因為「非自願性」一定是外在人力直接「威迫」所致的，而不是人所身處的客觀經濟地位。此種理解預設個人在無直接外力介入下為自主的個體，除去外力即維護了個人的自願性，例如2005年的ILO報告指出：

強迫勞動不能只是等同於低薪，也不包含純粹的經濟需要，亦即勞工認為無法離開工作，因為事實上沒有、或自認沒有其他就業的可能。強迫勞動是對人權的嚴重違反，與對人類自由的限制¹¹⁰。

這顯示ILO強迫勞動定義並不關注市場經濟內勞動自由與不自由的兩面性，貧困、沒有工作就無法生存的事實，只是外在的背景，而國家與雇主毋庸對背景情勢負責，除非經濟需求與其他雇主或政府有責的行為結合，政府與雇主才會因此構成強迫勞動¹¹¹，例如要求國家規定難民去做社會服務工作，否則無法維持社會福利資格。

又ILO為消除強迫勞動所出版的各種實務指引，出於個案判別、操作的需要，原則上亦以意願模式為核心。例如ILO為使調查人員估計強迫勞動受害者人數之用，而對強迫勞動所下之操作型定義為：在強迫（coercion）下所發生的非自願性（involuntariness）勞動¹¹²，不論勞動基礎法律關係是否為僱傭，其有4個主要面向，包括(1)「不自由的聘僱」（強迫與欺騙式的聘僱）、(2)「脅迫下的工作與生活」、(3)「無法離開雇主」與(4)「在勞工或其家人身上施

110 ILO, A GLOBAL ALLIANCE AGAINST FORCED LABOUR, *supra* note 105, at 5 (emphasis mine).

111 “However, the employer or the State are not accountable for all external constraints or indirect coercion existing in practice: **for example, the need to work in order to earn one’s living could become relevant** only in conjunction with other factors for which they are answerable.” ILO, ERADICATION OF FORCED LABOUR, *supra* note 31, at 20-21 (emphasis mine).

112 ILO, HARD TO SEE, HARDER TO COUNT: SURVEY GUIDELINES TO ESTIMATE FORCED LABOUR OF ADULTS AND CHILDREN 13 (2d ed. 2012).

加懲處威迫」的強制手段¹¹³。但在各層面ILO都一再區別雇主威迫行為與勞工本身弱勢處境與經濟需要。例如，不自由的聘僱是強制勞工違反其意願為特定雇主工作，但「貧困與家庭需要收入不是強制的徵兆，強制必須是由第三方所加諸的才算」¹¹⁴；類似地，若雇主扣留薪資，勞工怕失去既有薪資不得不繼續留下，這構成強迫勞動，反之如果「勞工因為貧困或缺其他所得來源的機會」而無法離開此職場，則不構成強迫勞動¹¹⁵。又如在濫用脆弱性層面，「單是沒有其他就業機會而得留在一個工作上，不是強迫勞動」，可是如果雇主明知、且利用這個情況，指派更極端的工作條件；亦即係因勞工受制於就業機會的匱乏，雇主才會加諸此種條件的話，那麼是強迫勞動¹¹⁶。凡此都顯示ILO對強迫勞動的界定，試圖止步在勞工背景條件的經濟危脆前，表現出意願模式不自由勞動的典型理解。

（二）意願模式下維護自願性的國家任務

那麼在意願模式的強迫勞動概念下，ILO認為國家為消除強迫勞動該做什麼呢？徵諸專家委員會的實踐，本文舉隅2個基本、直觀，且對臺灣有意義（見下文「肆」）的作為：一是應使強迫勞動違犯受到足夠嚴厲的制裁；二是移除對移工流動的過度限制。

1. 有效處罰強迫勞動犯行

C29第25條規定：「非法徵取強迫勞動當以刑法科罰，凡批准本公約之會員國，應使其法定懲罰，實屬適當並嚴格施行。」隨公約關注焦點從國家強迫勞動移轉到私人強迫勞動，第25條的重要性日增，成為最核心的國家人權保護義務¹¹⁷。

¹¹³ *Id.* at 14-16.

¹¹⁴ *Id.* at 14.

¹¹⁵ *Id.*

¹¹⁶ *Id.* at 16.

¹¹⁷ ILO, ERADICATION OF FORCED LABOUR, *supra* note 31, at 73.

何謂適當的法定懲罰呢？首先，法令規定須釋放這是嚴重人權違反的訊號，所以處罰須是刑事處罰，若只有短期刑或罰金，專家委員會認為強度過低，非嚇阻犯罪有效的處罰¹¹⁸。再者，專家委員會認為構成要件上，獨立、特定的行為規範，比一般性的行為規範合適，例如強迫勞動獨立成罪，較諸以一般強制罪處罰，更能清楚傳達禁止強迫勞動的訊息。對於特定容易導致強迫勞動的普遍行為，不妨獨立規定，以確立更清楚的行為界線¹¹⁹，例如沒收護照與扣留薪資。刑事立法必須足以涵蓋強迫勞動的所有行為態樣，以提供給被害人足夠的保護，而法院的解釋亦不應不當限縮立法所欲拘束和保護的對象¹²⁰。

在刑罰設計上，若以沒收強迫勞動之不法所得為從刑，抵銷行為人強迫勞動的經濟利益，專家委員會也提請成員國注意，受害人是否能確實獲得經濟賠償與扶助，避免再度成為受害者¹²¹；其亦鼓勵成員國定期公告被認定涉入強迫勞動或奴工的不法行為之自然人和法人名單，因為這有助於企業進行供應鏈管理¹²²。這些措施因為涉及制裁的設計，所以本文列為意願模式下之適當處罰作為。不過嚴格說來，賠償受害者與供應鏈管理，已屬於被害人保護和強迫勞動預防的面向，是呼應能力模式的人權作為。這顯示即使從較保守的意願自由定義出發，只要認真考慮被害人處境，在具體作法上即會朝向能力模式靠近。

118 ILO, REPORT OF THE COMMITTEE OF EXPERTS ON THE APPLICATION OF CONVENTIONS AND RECOMMENDATIONS, ILC 111/III(A) 384 (2023), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_868115.pdf. 專家委員會針對黎巴嫩家戶移工情況的建議。

119 ILO, ERADICATION OF FORCED LABOUR, *supra* note 31, at 74.

120 ILO, *supra* note 118, at 356. 針對巴西欲將勞動法處罰擴張至有損尊嚴的勞動條件、以債務限制勞工行動、將勞工拘禁於勞動處所等而引發政治反對，專家委員會所為之建議。

121 *Id.* at 357.

122 *Id.*

2. 去除移工流動的法律障礙

維持勞工行動自由與工作流動（job mobility）的可能性，可避免強迫勞動發生。專家委員會要求成員國禁止私人拘束移工行動自由的舉措、並檢視國家法律對於移工移動和職業自由的剝奪。例如移工一旦不持有自己的身分證件，會增加遭遇強迫勞動風險與離開強迫情境的難度，因此成員國除了應規定移工證件不得隨意由雇主取得外，亦必須確保申訴管道的暢通，及採取事實上避免證件移工離身的措施¹²³。

再者，針對離職意願的保護，過去波灣國家對移工採取贊助人（*kafala*）制度，移工的入境、居住、轉換工作、契約終止、出境，均受制於雇主的同意。*kafala*雖是極端的控制制度（如出境同意），但其中剝奪移工行動與轉換工作自由的類似設計，在暫時性移工制度中卻不少見¹²⁴。許多國家限制移工終止契約之事由，僅於雇主有特定違法時，許可移工終止契約轉換雇主。但當移工無權單方解約，加上許可轉換雇主的事由過於特定、狹窄，便易於陷入強迫勞動的情境¹²⁵。

就此，專家委員會首先要求，移工得終止僱傭契約的法定事由必須足夠寬廣，並確保這些事由下，移工都能轉換雇主而不需要離境。法定事由至少應該包含移工受到暴力（無論是否性暴力）、雇主不遵守契約、移工受到雇主或代理人的騷擾、移工繼續工作將有

123 *Id.* at 382. 如科威特雖然規定雇主非經家戶移工的同意，不得取得其身分證件，但是家戶移工本身的脆弱性與對雇主高度的依賴，使得專家委員會疑慮，家戶移工的「同意」非任意為之，因此敦促科威特政府採取確保任意性的有效措施，包括暢通之申訴管道。

124 Ryszard Cholewinski, *Understanding the Kafala Migrant Labor System in Qatar and the Middle East at Large*, with ILO Senior Migration Specialist Ryszard Cholewinski, GEORGETOWN JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS (Feb. 1, 2023), <https://gjia.georgetown.edu/2023/02/01/the-kafala-system-a-conversation-with-ryszard-cholewinski/>.

125 ILO, *supra* note 118, at 383.

害勞工安全衛生、移工在工作條件上遭到欺騙、雇主誣賴移工、雇主或代理人對移工有任何違反公共道德的行為等¹²⁶。其次，在法律上與實務上都需要支持移工，使其在權利受到侵害時，有權直接離開工作場所，而不受到逃跑的指控、處罰與遣返¹²⁷。但更根本的，專家委員會重視長時間契約中，移工應有經預告後（如2個月），無責單方終止僱傭並轉換雇主的權利，其明確指出長期契約若無法在合理預告期間後終止，則契約的合意性質不復存，即轉變成法律上的強迫勞動，而違反強迫勞動公約¹²⁸。

總之，上述措施無非是在保護個人自願性的前提下，懲治強迫犯行且在法令上維持勞工行動與終止契約的自由。但下文「肆」將會看到，臺灣移工制度就維持此種古典意義的自願性之措施，仍有改善空間。

三、ILO走向能力模式的軌跡

雖然ILO對強迫勞動的概念以意願模式為主，但是能力模式亦有單點的突破，部分係受到人口販運防制法制發展的影響，帶入對剝削與濫用弱勢地位的關注。具體實踐則表現在勞動法規樓地板的要求、全面人權進路的採取，以及公平招募的建議，以防止剝削和經濟弱勢之惡化。

¹²⁶ *Id.* at 383-84.

¹²⁷ *Id.* at 383.

¹²⁸ *Id.* 專家委員會指摘科威特不允許家戶移工在契約到期之前，未經雇主許可，在給予特定法定預告期間後，單方終止僱傭契約。
另參卡達與ILO技術合作改革*kafala*，移工轉職不再需要雇主同意，得在電子平台上申請轉職，經2個月預告後離職，並在平台上自動獲得勞動主管機關許可，申請轉職被駁回的案例多涉及新雇主無聘僱資格，而移工可以再次申請。ILO, *Labour Reforms in the State of Qatar: Coming Together Around a Shared Vision*, at 5 (Oct. 31, 2022), https://www.ilo.org/beirut/countries/qatar/WCMS_859843/lang--en/index.htm; ILO Project Office for the State of Qatar, *Progress Report on the Technical Cooperation Programme Between the Government of Qatar and the ILO*, at 5 (Nov. 13, 2023), http://www.ilo.org/beirut/countries/qatar/qatar-office/WCMS_901686/lang--en/index.htm.

（一）能力模式概念的進入：剝削與濫用弱勢地位

1. 人口販運定義的影響

國際人口販運法制發展的開端是對跨國性產業的抵制。販運的核心訂在剝削，而非強迫與否，因為有些倡議者所關注的，並非是否「逼良為娼」，而在於性產業中惡劣勞動條件、虐待和經濟掠奪；相對地有些倡議者則認為性工作永遠不可能是自願¹²⁹。而抵制人口販運的倡議，與冷戰後若干主權國家（尤其美國、義大利、波蘭）希望強化邊境管制、緊縮移民流動、消除偷渡、毒品走私、組織犯罪與反恐等顧慮合流¹³⁰，運用打擊販運的修辭，可擴及不違反意願的犯罪，擴大邊境控制與國家合作範圍。

當不強調被害人意願之違反的人口販運法制¹³¹，開始影響到強迫勞動之防制時，乃使後者往能力模式移動。首先是在人口販運定義下，剝削與強迫被連結起來。UN《打擊跨國有組織犯罪公約關於預防、禁止和懲治販運人口特別是婦女和兒童行為的補充議定書》（Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations

129 Marjan Wijers, *How We Got Here: The Story of the Palermo Protocol on Trafficking*, OPENDEMOCRACY (Feb. 11, 2021), <https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/how-we-got-here-story-palermo-protocol-trafficking/>. Wijers 是國際人口販運發展的倡議者之一，參與議定書草擬的過程，本文談及議定書討論期間的歧見，包括應以強迫抑或剝削為核心之爭議，而將強迫放在剝削之下的類別之一，是爭議下的妥協。

130 Ian Tennant, *Fulfilling the Promise of Palermo? A Political History of the UN Convention Against Transnational Organized Crime*, 2 J. ILLICIT ECON. & DEV. 53, 55-60 (2021).

131 議定書第3條(b)項：「如果已使用本條(a)項所述任何手段，則人口販運活動被害人對……剝削所表示的同意並不相干」。但所謂人口販運不強調被害人一定是非自願的說法，並不表示人口販運定義與實務中都不考慮自願的違反。有論者仍強調人口販運的不法手段必然嚴重到使被害人表面自願失去意義，所以終究是被迫。ANNE T. GALLAGHER, *THE INTERNATIONAL LAW OF HUMAN TRAFFICKING* 32 (2010).

Convention Against Transnational Organized Crime，下稱人口販運議定書）所稱之人口販運，一言蔽之，指為剝削被害人，以不法手段使被害人移徙、留置於他處¹³²。當中3個要素是¹³³：

- a. 販運過程，即對人的招募、運輸、移轉、容留、接收等。
- b. 販運手段，即實施販運過程的不法方法，如威脅、強迫、綁架、詐術、欺騙、濫用權力或被害人的脆弱性等。
- c. 剝削目的，議定書未對剝削下一般性定義，而列出三種目的類型，分別為勞力剝削、性剝削與器官摘取，而勞力剝削包含強迫勞動、奴役或類似奴役等。

如前所述，對意願模式而言，剝削和自願性沒有必然關連，強迫勞動原本側重在自願與否，而剝削涉及分配結果之公平性，也因此ILO對強迫勞動，傳統上不太談剝削¹³⁴。然而儘管人口販運與強迫勞動要件有別，不完全重疊¹³⁵，且基於國際組織對各自任務的尊重，不會改變強迫勞動的法律定義，但因強迫勞動納為人口販運定義下勞力剝削目的之一種，剝削開始較頻繁地進入到ILO討論強迫勞動的文件中¹³⁶，ILO年度報告也會在強迫勞動公約項下，調查各國對人口販運的處理並予以回應。因此國家防制人口販運和消除強迫勞動的任務會有所重疊，特別是對跨境流動的移工，二者有共通

¹³² Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, art. 3(a), Nov. 15, 2000, 2237 U.N.T.S. 319 (entered into force Dec. 25, 2003).

¹³³ United Nations Office on Drugs and Crime, *The Crime: UNODC is the Leading Entity within the United Nations System to Address the Criminal Elements of Human Trafficking*, UNITED NATIONS, <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html> (last visited Nov. 18, 2023).

¹³⁴ Judy Fudge, *(Re)Conceptualising Unfree Labour: Local Labour Control Regimes and Constraints on Workers' Freedoms*, 10 GLOB. LAB. J. 108, 114 (2019).

¹³⁵ GALLAGHER, *supra* note 131, at 49-50. 批評ILO將強迫勞動認為是包含人口販運、比人口販運更廣的上位概念。

¹³⁶ Fudge, *supra* note 134, at 114.

的現實因素。而ILO對剝削的注意與回應，是其往能力模式移動的現象。

2. 人口販運與強迫勞動指標的影響

ILO對強迫勞動的想像，逐漸納入能力模式之關懷的現象，亦可從人口販運的指標與強迫勞動指標的運用中看到。二種指標的共通要素包括剝削與濫用弱勢處境，而使「經濟性強迫」進入強迫勞動的視野中。指標雖不會改變、也不能取代法定定義，但會影響對國家應採何種措施的理解。以下依次說明人口販運與強迫勞動指標中對經濟危脆的關注。

先看人口販運指標：2009年ILO與歐洲聯盟執委會（European Commission, EC）為協助第一線人員與研究辨識人口販運案件，共同發展「人口販運操作指標」（或稱為「德爾菲指標」（Delphi indicators）¹³⁷），內含6個面向，每個面向下有強、中、弱指標¹³⁸（參表1）。6面向分別是「欺騙招募指標」、「強迫招募指標」、「目的地強迫指標」、「剝削指標」、「濫用弱勢處境招募指標」、「目的地濫用弱勢處境指標」。前3個面向可為傳統意願模式所涵蓋；後3個面向則涉及能力模式對不自由勞動的理解。

¹³⁷ 稱德爾菲指標係因該指標是運用德爾菲方法（Delphi method）產生，即透過廣泛徵求專家之共識，決定人口販運的徵兆和強度。ILO Special Action Programme to Combat Forced Labour [hereinafter SAP-FL], *Operational Indicators of Trafficking in Human Beings*, at 2 (May 4, 2009), http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_105023/lang--en/index.htm. 此文件無頁碼，所標頁碼為pdf檔的頁數。

¹³⁸ 指標的使用方法是針對6個面向個別獨立評估，一個面向內若有2項強指標、1項強指標搭1項中指標、3項中指標，或2項中指標搭1項弱指標，即為成立，最後再綜合評估當事人的整體狀況。Id. at 3.

表1 對成人以勞動剝削為目的之人口販運指標

面向	指標強度	指標內容
欺騙招募（deceptive recruitment）指標	強指標	欺騙工作性質、地點或雇主
	中指標	欺騙工作條件 欺騙僱用契約的內容或合法性 欺騙有關家庭團聚 欺騙居住或生活條件 欺騙法律文件或獲取移民地位 欺騙有關旅行或招募條件 欺騙薪資收入 欺騙結婚或收養的承諾
	弱指標	欺騙有教育機會
強迫招募（coercive recruitment）指標	強指標	對被害人施暴
	中指標	挾持 強迫婚姻 強迫收養或販賣被害人 沒收文件 債務約束 孤立、限制行動或監視 威脅向主管機關檢舉 威脅對被害人施暴 威脅通知家庭、社區或公諸於世 對家庭成員（威脅或實際）施暴 扣留金錢
濫用弱勢處境招募（recruitment by abuse of vulnerability）指標	中指標	濫用家庭困難情境 濫用不合法地位 濫用欠缺教育（語言） 濫用欠缺資訊 剝削者的控制 經濟理由 法律或主管機關態度的錯誤資訊 成功遷移的錯誤資訊 家庭狀況

		個人狀況 心理或情感上的依賴 與主管機關／法律地位的關係
	弱指標	濫用文化／宗教信仰 一般脈絡 過去的困難 籌劃旅程的困難
剝削（exploitation）指標	強指標	過長工作時日
	中指標	惡劣生活條件 危險工作 低薪或無薪 無視勞動法令或勞動契約 欠缺社會保障（包括契約、社會保險等） 很差的工作條件 操控薪資
	弱指標	無從受教育
目的地強迫（coercion at destination）指標	強指標	沒收證件 債務約束 孤立、限制行動或監視 對被害人施暴
	中指標	強迫涉入非法或犯罪活動 強迫性的任務或客戶 強迫背叛（act against）同僚 強迫對主管機關或家庭撒謊 威脅向主管機關檢舉 威脅給予更惡劣的工作條件 威脅對受害者施暴 受到強烈影響 對家庭成員（威脅或實際）施暴 扣留金錢
	弱指標	威脅通知家庭、社區或公諸於世

目的地濫用弱勢處境 (abuse of vulnerability) 指標	中指標	依賴剝削者 生活在未知區域的困難 經濟理由 家庭狀況 和主管機關的關係／法律地位
	弱指標	過去的困難 個人特質

資料來源：SAP-FL¹³⁹。

從人口販運指標（表1）可以觀察到，經濟危脆現象透過若干有關弱勢處境與剝削的指標，而進入到販運案件的判斷。首先關於弱勢處境，人口販運指標所列甚廣，有非經濟性的弱勢¹⁴⁰，例如法律地位、語言、資訊的欠缺，對剝削者的依賴等，但也有經濟上的危脆，包含屬「濫用弱勢處境招募」中指標的「家庭困難」，即當事人是全家生計之所繫，與「經濟理由」，即貧窮（含經濟上無法負擔返家交通費用）、負債、需扶養家庭成員或親戚，或來自沒有工作機會之處¹⁴¹。

其次「剝削指標」面向則廣泛涉及工作與生活條件。強指標「過長工作時日」指被迫加班、沒有休息、或全時全日待命，要求單位時間內過高的生產量亦屬之。中指標如「惡劣生活條件」，包括無法選擇住所、住所過擠、不健康不衛生、欠缺隱私，也包括剝奪住所；「危險工作」包括欠缺安全措施的危險工作環境，工作環境太冷太熱、工作太髒等；「低薪或無薪」中，無薪包括以實物給

¹³⁹ SAP-FL, *supra* note 137, at 4. 中文為筆者自譯。

¹⁴⁰ 如受招募時家庭關係惡劣、無合法移民地位、欠缺所需的語言與正確資訊、遭到幫派控制、社會污名、無法備辦移徙所需文件；或在目的地時，日常生活、行動與外界接觸均需依靠剝削者。SAP-FL, *Explanations for Indicators of Trafficking for Labour Exploitation*, at 3-4 (Apr. 21, 2009), <https://www.ilo.org/publications/explanations-indicators-trafficking-labour-exploitation>. 此文件無頁碼，所標頁碼為pdf檔的頁數。

¹⁴¹ *Id.* at 3.

付代替貨幣給付，低薪則指所獲薪資低於合意或低於最低工資；「無視勞動法令或勞動契約」包括契約或聘僱不合法、或薪資低於其他勞工；「欠缺社會保障」除了指無從投保，也包括在生病或狀況不適合工作時被迫工作；「很差的工作條件」主要指被迫接受難以接受的工作條件；「操控薪資」指各種給付不透明或苛扣，如付給中間人、扣除罰金、太高的食宿費用、以及對薪水無掌控或不能免費存款等¹⁴²。以上許多是臺灣移工工作環境中常見的現象（見下文「肆」）。

除了剝削與濫用弱勢處境面向觸及經濟必需外，亦值得注意的是，在「強迫招募指標」之面向中有三項指標會涉及制度因素：孤立（如難以和外界溝通，沒有手機等，被留置在某處，行動自由受限）、檢舉（如不付薪水而予以遣返）¹⁴³與債務約束。所謂制度因素，指這類行為有些可能是合法的、甚至受到法律鼓勵（見下文「肆」），然而毋寧會構成強迫手段，須改變制度設計才能有效應對。特別是債務約束（在「強迫招募」與「目的地強迫」面向下的中指標）是典型的經濟危脆現象，也是能力模式所關注的不自由核心。在此，債務本身即是發生強迫的指標，不單是一種脆弱處境；再者，操縱債務（如利率過高、不合法不透明的抵償）會加重債務約束，但並不是有操縱才算債務約束¹⁴⁴。

次看強迫勞動指標：ILO繼2009年與EC共同發展人口販運指標之後，於2012年亦為第一線人員在勞動現場辨識出強迫勞動案件及受害人所需，發展強迫勞動指標作為協助工具¹⁴⁵，內容較簡化，但仍與人口販運指標多所呼應。該指標實際上也為臺灣行政體系所熟

¹⁴² *Id.* at 4-5.

¹⁴³ *Id.* at 6.

¹⁴⁴ *Id.* at 2, 6.

¹⁴⁵ SAP-FL, *ILO Indicators of Forced Labour*, at 2 (Oct. 1, 2012), https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_203832/lang-en/index.htm. 本文件無頁碼，所標頁碼為pdf檔頁次。

稔，其經行政院防制人口販運協調會報要求，下達各地勞動行政主管機關與外籍勞工相關人員知照¹⁴⁶。

ILO強迫勞動的11項指標絕大多數都在協助辨識以不法或不當手段，扭曲勞動意願的情境，包括欺騙、限制行動、孤立、身體或性暴力、恐嚇威脅、扣留身分文件、扣留薪資，再度顯示ILO強迫勞動概念以個人意願為基底。但是濫用弱勢處境、債務約束、苛刻工作或生活條件、過度加班幾項指標，則觸及經濟因素導致的強迫和剝削，並且潛在需導入能力模式的思維與制度變革以求應對。

例如ILO對濫用弱勢處境指標的說明裡，如同人口販運指標一般，指出弱勢地位包括經濟上危脆。儘管ILO再次強調單純處於弱勢處境，例如沒有其他工作機會，不是強迫勞動，惟「一旦雇主利用勞工的弱勢處境而例如加諸過度的工時或扣留薪水，即可能構成強迫勞動」¹⁴⁷，亦即以雇主的不當利用行為，來區別單純危脆狀態跟強迫勞動，似乎保留了意願模式的外觀。但值得注意的是，濫用弱勢指標的運用，往往有賴健全勞動規範的背景建置，而自然指向能力模式的關懷。

因為何謂濫用，須仰賴對於何謂公平交易條件、以及哪些脆弱情境不得遭利用的判斷。在市場競爭中，利用對手弱點可能完全正當，如商戰中趁競爭對手資金窘迫而加碼投資，看準交易對手需求孔急而提出較差條件等。但在勞動市場中，避免市場力量不均所致的惡劣勞動條件，則是勞動法長久的核心任務之一¹⁴⁸。在有完善公平勞僱條件規範的市場中，不僅較容易判斷雇主有無濫用脆弱性，也較易確保勞工即便處於經濟危脆，仍不陷入被濫用的境地。剝削

146 內政部移民署，行政院防制人口販運協調會報第29次會議紀錄，頁2，2015年10月29日，<https://www.immigration.gov.tw/media/34479/行政院防制人口販運協調會報第29次會議紀錄.pdf> [<https://perma.cc/8XT4-3QXE>]。

147 SAP-FL, *supra* note 145, at 5.

148 GUY DAVIDOV, A PURPOSIVE APPROACH TO LABOUR LAW 52-54 (2016).

指標亦有類似特性，生活條件是否過苛、加班是否過度，主要會遵循各國法令之樓地板來判斷，在有法令標準可循的狀況下，判斷與防制都會較為容易。換言之，對這類指標的關注，顯露出能力模式認為自由勞動需以勞動法令建置為條件的思維。

（二）能力模式下的作為

那麼ILO認為國家應採取的哪些作為，可視為能力模式下的舉措呢？本文舉隅3點，一是最核心的，須避免脆弱處境惡化與法令勞動條件的建立；二是2014年之《1930年強迫勞動公約之議定書》所反映的人權路徑；三是對應對債務約束與經濟危脆重要的公平招募一般原則。

1. 健全勞動法令與確切執行

專家委員會報告中常見指出移工陷入「等同於強迫勞動的工作條件」¹⁴⁹的情境，這意謂太惡劣的工作條件（本來未必是自願性問題），可能涉嫌強迫勞動。而遭委員會指摘的惡劣條件，不僅有損及自願性的情況，如沒收護照、不付薪水¹⁵⁰、遭到身體虐待¹⁵¹，也有未必直接傷害自願，惟勞動保護基礎建設不足的情形，如過長工時、無職業安全保障¹⁵²等。委員會乃要求成員國避免脆弱處境的制

149 如“conditions tantamount to forced labour”或“conditions of work that amount to forced labour”，因前後文不同有時用語稍微出入，但這是專家委員會報告中很常見的表述。

150 *E.g.*, ILO, ADDENDUM TO THE 2020 REPORT OF THE COMMITTEE OF EXPERTS ON THE APPLICATION OF CONVENTIONS AND RECOMMENDATIONS, ILC.109/III/ADD.(A) 293 (2021), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_771042.pdf. 委員會敦請沙烏地阿拉伯政府強化法律架構，確保不增加移工的脆弱性，避免移工遭受到等同於強迫勞動行為，如沒收護照與不付薪水。

151 *E.g.*, ILO, *supra* note 118, at 392. 針對在馬來西亞境內移工處境之批評。

152 *E.g.*, *Id.* at 365. 哥斯大黎加的勞工組織報告許多尼加拉瓜無證移工在鳳梨與甘蔗田工作，薪水低於承諾、一天工時長達12小時，沒有社會安全保障，不符合職業安全衛生條件，欠缺食物或資金返國，不敢檢舉田間違法狀態以免被

度因素，建立勞動法令¹⁵³，並強化勞動檢查以切實執行法令¹⁵⁴，且勞動法令的保護不得因為勞工的移民身分不同而有所差異¹⁵⁵，即令移工輸出國對其本國國民也有保護義務¹⁵⁶，避免其陷於脆弱處境。

以在馬來西亞境內之移工處境為例，ILO專家委員會認為移工所面臨的強迫勞動處境惡劣，應改善之處包含許多制度性變革，但最基礎的是勞動法令貫徹。委員會指出馬來西亞境內移工之工時很長，平均一天10小時，平均每週6.2天，所得遠低於最低工資，並常見強迫性僱傭行為，如扣留證件、過度加班，而移工欠缺公平有效、具可近性的救濟管道¹⁵⁷。委員會並援引2020年UN極端貧窮與人權特別專員的調查，指出馬來西亞2至3百萬移工遭護照沒收、薪資低於最低工資、被罰款，高額招聘費用、對仲介與雇主負債、薪資苛扣，移工遭虐待等案件汗牛充棟，且勞動法令並未確實執行，

遣返。委員會認為這構成勞動剝削的人口販運，要求政府須無視移民地位，為被害人提供立即全面的協助和保護。

153 E.g., ILO, REPORT OF THE COMMITTEE OF EXPERTS ON THE APPLICATION OF CONVENTIONS AND RECOMMENDATIONS, ILC.110/III(A) 330 (2022), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836653.pdf. 委員會要求巴林政府，避免家戶移工處於等同於強迫勞動的工作條件，包括家戶移工應適用勞動法保護。

154 *Id.* at 325-26. ILO專家委員會要求亞塞拜然移工制度的設計不可將移工置於更脆弱處境，敦請政府提供高度運用移工的行業如建築、農業與家戶，進行勞動檢查的數據。

155 E.g., ILO, REPORT OF THE COMMITTEE OF EXPERTS ON THE APPLICATION OF CONVENTIONS AND RECOMMENDATIONS, ILC.108/III(A) 223 (2019), https://ilo.primo.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/41ILO_INST:41ILO_V2/1258339380002676. 委員會指出在哈薩克境內的吉爾吉斯無證移工處境惡劣，政府雖主張法律禁止歧視合法在哈薩克境內工作的外國人，但委員會敦促政府應採取有效手段避免增加移工的脆弱性，如證件被沒收、行動受限、危險工作環境、或遲延給付薪資。

156 E.g., ILO, *supra* note 150, at 224. 委員會敦請菲律賓政府保護其在海外工作的國民，不受等同於強迫勞動的工作條件。ILO, *supra* note 118, at 404. 尼泊爾政府為使自身國民能安全外移工作，與目的地簽訂備忘錄，但委員會仍敦請政府持續提供保護移工之相關法律的執行狀況資訊，並有效避免移工被困在如同強迫勞動的工作條件中。

157 ILO, *supra* note 155, at 229.

上開情況多年來均未改善¹⁵⁸。就此委員會敦促馬來西亞強化勞動檢查，切實貫徹勞動法令，提升執法機關的執法能力，促進不同執法機關間的合作與聯繫¹⁵⁹。這些建議舉措看似基本，卻有重要理論意義：勞動法令和執行之缺席，不單純是工作條件問題，而是會導致強迫勞動的制度因素；法令的制定與執法的健全，是對抗剝削與濫用弱勢處境指標的必要之舉。

2. ILO 2014年之《1930年強迫勞動公約之議定書》

第二個面向是《1930年強迫勞動公約之議定書》¹⁶⁰（下稱P29）所代表的全面人權取徑的興起。ILO在2014年以近全數同意的高度共識通過P29¹⁶¹，補充強迫勞動公約相關國家人權義務¹⁶²，這彌補了國際人權裡一個重要的空缺：亦即儘管有許多國際公約要求各國消除強迫勞動，但卻無文件系統性地提出，國家有何具體之強迫勞動侵害防止與保護、救濟被害人的人權義務，這個空缺在P29之後補上¹⁶³。

P29在草擬過程中，有UN毒品和犯罪辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime）及人權事務高級專員辦事處（Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights）代表參

¹⁵⁸ ILO, *supra* note 118, at 392.

¹⁵⁹ *Id.* at 392-93.

¹⁶⁰ Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930, June 11, 2014, 3175 U.N.T.S. 199 (entered into force Nov. 9, 2016), https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029 [hereinafter Forced Labour Protocol].

¹⁶¹ 政府代表除泰國外全數同意（但泰國政府事後表示投錯票），並只有6個雇主團體代表投票反對。Sweepston, *supra* note 40, at 413.

¹⁶² 議定書和公約一樣是具有拘束力、可供批准的國際條約，但議定書意在補充特定公約，因此只有已批准公約之成員國得批准議定書。ILO, *NORMLEX User Guide*, NORMLEX, <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:71:0> (last visited Nov. 27, 2023).

¹⁶³ Sweepston, *supra* note 40, at 404.

與¹⁶⁴，加上其在相對短時間內獲得大會高度支持，標誌了UN處理人口販運議題的相關機構、ILO及其成員國，對強迫勞動的應對，有相當共識，欲從單純處罰嚇阻的「處罰取徑」，轉向要求國家積極處理根源因素、以被害人福祉為核心（如重視救濟補償和徹底脫離強迫勞動處境）的「人權取徑」¹⁶⁵。此亦表示在人口販運成為國際執法焦點的年代，設計來應對強迫勞動的措施，必然納入對人口販運防制的考量，二者措施面會相互影響。

申言之，P29開宗明義指出，強迫勞動公約的義務履行，除了制裁違犯者外，會員國須採取有效預防及消除強迫勞動的措施，並保護受害者，提供有效救濟及賠償¹⁶⁶，其並建議國家設定國家行動計畫，設下可行的時間表以達成優先的目標。就「預防」，P29要求成員國提升勞雇雙方的教育訓練，避免其涉入強迫勞動；制定並執行涵蓋所有勞工、所有經濟部門的勞動法令和其他能防止強迫勞動的規範（如社會安全）；鼓勵公私部門對強迫勞動風險進行盡職調查；在招募過程中保護移工不遭到虐待與強迫，解決會提高強迫勞動風險與脆弱性的根本因素¹⁶⁷——在本文脈絡中，也代表國家不得設計會升高強迫勞動風險的移工制度。預防措施在在顯示，國家應對強迫勞動的任務不再能限於意願模式的理解，而必然涉入能力模式對改善制度背景的關切。

就「保護」與「救濟」，P29要求成員國加強對強迫勞動被害人的識別，提供各種協助，使其脫離強迫勞動處境，從中復原，並回復工作；協助被害人近用有效救濟，無論其法律身分，均能獲得補償，並允許執法人員裁量不追訴強迫勞動被害人所涉違犯¹⁶⁸。

¹⁶⁴ *Id.* at 416.

¹⁶⁵ *Id.* at 405.

¹⁶⁶ Forced Labour Protocol art. 1.

¹⁶⁷ Forced Labour Protocol art. 2.

¹⁶⁸ Forced Labour Protocol arts. 3 & 4.

對於批准P29的成員國，專家委員會關注議定書在預防、被害人辨識補償救濟的進展。例如馬來西亞，委員會一方面讚許其批准議定書後，擬定強迫勞動國家行動計畫（包括法律意識提升、促進執法、改善招聘制度、提供救濟），且在ILO技術協助下，與移工來源國建立國對國的移工引進系統¹⁶⁹，從制度上預防移工遭仲介費剝削或招募時之強迫或欺騙風險。但另一方面委員會也指出馬來西亞對移工仍充滿歧視，表現在公共服務不足、公眾支持對移工加諸社會排除的法律、拒絕給予移工同工同酬等¹⁷⁰，委員會因此敦促馬來西亞政府加強教育、預防與合作：提升移工勞動權益的意識，讓大眾知悉移工的處境，以改善社會對於移工的歧視態度，與移工輸出國有更多合作和協議，並提供強迫勞動被害人救濟與協助等¹⁷¹。

又如英國於2016年批准P29，英國工會聯盟就其執行提出相關指摘，包括低落的人權盡職調查，與揭露被害人的無證地位所造成的保護漏洞。委員會乃重申在P29第4條下所有強迫勞動被害人，無論法律地位均應獲得有效救濟與賠償，敦請英國政府確保移工不陷入脆弱處境，暴露在剝削風險下¹⁷²。

但是，即便是沒有批准P29的成員國，委員會仍會視該國的狀況，指引其採行人權取徑下的相關措施，例如委員會持續敦促土耳其政府加強對受害人的辨識、充實保護機關的訓練與資源¹⁷³。重要的終究是成員國負有徹底消除強迫勞動的義務，而欠缺相關措施則無法竟功。

169 ILO, *supra* note 118, at 391. 截至2022年已和印尼、孟加拉、越南簽訂備忘錄，並持續和柬埔寨、印度、斯里蘭卡、尼泊爾和泰國協商。

170 *Id.* at 392.

171 *Id.* at 392-93.

172 ILO, *supra* note 150, at 311-12. 英國工會聯盟指出，英國2015年的現代奴隸法雖要求企業說明打擊現代奴隸所採之盡職調查措施，但即使企業明說未有措施也能過關。又第一線通報人員訓練不足，未能充分辨識與支持受害者，本應提供被害人協助的單位卻與移民機關共享資訊，有害提供保護的目的。

173 *Id.* at 307.

3. 公平招募一般原則

移工招募與跨國移動的管理，是避免強迫勞動與人口販運的重點¹⁷⁴。對仲介的管理不足，無論是移工輸出國與輸入國的失靈，都會加劇移工遭到債務約束與陷入強迫勞動工作條件的風險¹⁷⁵。ILO 乃在2019年公布〈公平招募一般原則〉(General Principles for Fair Recruitment)，其核心精神是要求「不得令勞工或求職者支付或以其他方式負擔招募費及相關費用」¹⁷⁶。

所謂「招募費」(recruitment fees)指求職過程中為獲得僱傭所付之費用，包括招募、轉介與派工(placement)服務，項目可能包含廣告、發送資訊、安排面試、繳交文件以獲得政府許可、認證資格、籌劃行程交通與派工。無論是一次或分次收取、收取時間地點、透過仲介、雇主或第三人收取、直接收取或從所得中扣除，均不影響招募費的性質¹⁷⁷。公平招募一般原則對招募費未設有得由求職者支付的例外。

而所謂「相關費用」(related costs)則包括但不限於醫療費用(如健康檢查)、保險費用、技能檢定費用、訓練費用、設備費用、

¹⁷⁴ 但亦有對邊境管理持批判立場的論者，主張邊境管理增加移民工跨國流動的障礙與成本，正是使其必須依賴販運集團或私人仲介始能進入他國勞動市場的始作俑者，所以管理不會是解方，*E.g.*, Davidson, *supra* note 95。公正招募一般原則主要是對跨國流動過程收費的管理與成本分配，未能完全回應上述批評，但在ILO不挑戰國家邊境管理主權的前提下，仍是比較可行的倡議方向。

¹⁷⁵ 關於輸出國的例子，UN移工公約委員會(Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)指出印尼不能保護其在外國工作之國民而有違反移工公約之嫌，ILO專家委員會乃要求印尼政府必須建立有效的私人仲介管理系統，以免增加移工受到強迫勞動的脆弱性，ILO, *supra* note 155, at 217。至於輸入國的例子見下文。

¹⁷⁶ “No recruitment fees or related costs should be charged to, or otherwise borne by, workers or jobseekers.” ILO, GENERAL PRINCIPLES AND OPERATIONAL GUIDELINES FOR FAIR RECRUITMENT AND DEFINITION OF RECRUITMENT FEES AND RELATED COSTS 13 (May 22, 2019), http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_536755/lang--en/index.htm.

¹⁷⁷ *Id.* at 28.

旅行與食宿費用、行政規費¹⁷⁸。相較於招募費均不得由求職者支付，相關費用若在事先以法律明訂、符合國際勞動法且經諮詢最有代表性的勞資團體後，得例外規定由移工支付¹⁷⁹。

公平招募一般原則並無拘束力，只是參考性的行動準則，然而專家委員會仍會敦請招募管理失能的成員國採行之。例如卡達在2014年遭控違反C29，隨後ILO與卡達政府進行技術合作處理強迫勞動¹⁸⁰，包括改善招募程序。卡達政府的改善報告指出，其禁止仲介對海外移工收招募費，否則將吊銷執照，不得收費的規定也寫進與移工的契約，仲介必須確保合作的外國仲介亦合法，政府並進行無預警抽查。卡達亦與孟加拉合作對建築工人推動免招募費計畫¹⁸¹。委員會則持續敦促卡達政府貫徹公平招募，不對移工收費¹⁸²。

四、小結：ILO實踐作為能力模式的共識

總結上述發展，ILO強迫勞動的定義謹守意願模式，關注非經濟性的脅迫。在意願模式下，成員國應以刑罰處罰強迫勞動犯行，並建議對強迫勞動的高度風險行為予以獨立成罪，以釋放明確訊息；亦應避免不當限縮禁止移工終止僱傭之法令，允許移工在單方定期預告後離職並轉職。但是受到人口販運定義與指標運用影響，進一步往能力模式的關懷靠攏，強迫勞動的判定滲入剝削和工作條件的考量，政策上須回應經濟危脆地位所致的不自由。具體措施包括制定勞動條件的法令樓地板，進行有效勞動檢查與執行；採取制

178 *Id.* at 29.

179 *Id.* at 28-29.

180 ILO, REPORT OF THE COMMITTEE OF EXPERTS ON THE APPLICATION OF CONVENTIONS AND RECOMMENDATIONS, ILC 109/III(A) 227 (2020), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_736204.pdf. 除此之外，卡達與ILO的技術合作亦包括改善薪資、加強勞動檢查與職業安全衛生系統、以契約取代*kafala*、加強強迫勞動的預防與處罰等。以上均顯示基本勞動法令建立與貫徹，對消除強迫勞動的重要性。

181 *Id.* at 228.

182 ILO, *supra* note 150, at 286.

度性預防措施，包括社會安全網、充分公眾教育、人權盡責調查；及遵循公平招募一般原則，避免讓移工支付招募費。

不可諱言，ILO以意願模式為核心的底蘊，乃引發許多能力模式論者抨擊：包括只將消除強迫勞動視為意願保護議題¹⁸³；認為強迫勞動違犯只是個案的偏差¹⁸⁴，不正視全球化資本主義經濟體制持續複製的經濟不平等，如何系統性地創造強迫勞動的沃土¹⁸⁵，並忽略法律制度如何導致對人的剝削與虐待¹⁸⁶。

平心而論，ILO並非沒有關注到強迫勞動具有經濟體制與法律制度上之因素，其亦表示強迫勞動最根本主要成因是「貧窮、不平等與歧視」¹⁸⁷。但ILO意願模式的價值判斷的確不基進，在保護自願的強迫勞動定義（意願模式），和強調提升能力的舉措（能力模式）之間，亦存在張力與衝突，未必能兩全，下文臺灣個案中會再度看到此種衝突。

ILO作為國際組織，其組成與決議方式，自然塑造其保守之取徑。正面而言，不基進的路線確保ILO公約與實踐反映出受廣泛支持的國際共識¹⁸⁸：在組成上，ILO大會由政府代表（每國2席）、勞工團體代表（每國1席）與雇主團體代表（每國1席）共同決議¹⁸⁹。由非政府代表與政府代表共決的設計，在UN組織中絕無僅有，目

183 Strauss, *supra* note 72, at 140.

184 Fudge, *supra* note 62, at 415.

185 Lerche, *supra* note 93, at 430-31.

186 Bridget Anderson & Ben Rogaly, *Forced Labour and Migration to the UK*, COMPAS, UNIVERSITY OF OXFORD 47-49 (Jan. 1, 2005), https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/PR-2007-Forced_Labour_TUC.pdf.（以英國的移民規定為例，說明不同的移民身分如何導致強迫勞動風險。）

187 ILO, *supra* note 102, at 11.

188 IAN HURD, *INTERNATIONAL ORGANIZATIONS: POLITICS, LAW, PRACTICE* 189 (4th ed. 2020).

189 Constitution of the International Labour Organization art. 3, ¶ 1.

的係使勞動標準在國際舞台折衝時，已有內國利益團體之參與，有助日後獲得內國政治認可¹⁹⁰。

在決議方式上，公約需與會代表票數的三分之二始能通過¹⁹¹。儘管ILO公約如同其他國際公約，大會通過後還須經各國批准始拘束該國，但對不樂見的公約內容，成員國仍有動機積極表態以阻止大會通過，因為除批准所生的個別公約義務外，成員國對ILO亦有本於成員地位所負之一般報告義務：即在每個公約通過之會期結束一年內，呈請國內有權機關討論落實公約之立法，與是否批准，如不批准應向ILO回報對公約議題具體的作法¹⁹²。故成員國雖無義務批准個別公約，但報告義務仍使其須對公約內容做政治表態。其若不贊同，自會反對通過以免產生報告義務¹⁹³。從而，公約欲通過表決，須獲得不同發展階段、對勞動標準熱衷程度不等之國家的廣泛支持，而遭論者評為「合理的中下標準」¹⁹⁴，亦即ILO多選擇降低野心，犧牲勞動標準「向上提升」的幅度，換取盡可能提高成員國遵守的意願¹⁹⁵。

最後，就公約之監督執行，我國學者多認ILO機制孱弱¹⁹⁶，但ILO監督程序係為了發展解方、促進對話、凝聚共識與技術合作，其有效性建立在三方對話的共識的正當性¹⁹⁷，制裁並非ILO所長¹⁹⁸。

190 HURD, *supra* note 188, at 179.

191 Constitution of the International Labour Organization art. 19, ¶ 2.

192 Constitution of the International Labour Organization art. 19, ¶ 5.

193 HURD, *supra* note 188, at 177.

194 *Id.* at 189.

195 *Id.* at 173.

196 徐揮彥（註24），頁86；焦興鎧，規範外籍勞工國際勞動基準之發展趨勢——兼論對我國之影響，月旦法學雜誌，90期，頁214（2002年）。

197 Monique van Alphen Fyfe & Guy Fiti Sinclair, *Supervisory and Review Procedures: International Labour Organization (ILO)*, in MAX PLANCK ENCYCLOPEDIAS OF INTERNATIONAL LAW ¶ 4 (Apr. 2020), <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-mpeipro/e1617.013.1617/law-mpeipro-e1617> (last visited Dec. 18, 2023).

198 Brian A. Langille, *What Is International Labor Law For?*, 3 LAW & ETHICS HUM. RTS. 47, 79 (2009).

專家委員會對於公約實踐的審查因此著重在提供建議與支援，鼓勵成員國逐步提升標準。

綜上，ILO不以基進為要，亦不挑戰主權國家根本經濟秩序，但ILO的謹慎路線，實則為能力模式提供了有用的資源，因為能力模式的困難是，不易決定什麼樣的合理選項與背景條件才稱得上是自由的勞動，而ILO公約與實踐提供勞動標準與具體作法的廣泛共識，有助避開上位的社會正義爭論，而由特定的措施改善著手。消除強迫勞動看似有限目標，而ILO則在有限目標中追求最大發展。

肆、臺灣移工制度的強迫勞動風險

最後，本節從ILO C29相關見解檢視臺灣移工制度。移工制度30年來文獻豐富，本文對論者詳為指摘之處不再贅言，而將重點放在說明：臺灣官方（包括行政、立法與司法），對消除強迫勞動任務的理解，原則上亦以意願模式為範圍，並較抗拒來自能力模式的訴求。

不過，在進入分析正文前，須指出的是，以下有關國內法抗拒能力模式的觀察與批評，並非預設凡是能力模式的立法就是好的（文獻上對典型採能力模式之國際人口販運防制發展的批判，長篇累牘），或凡是意願模式的立法就是不好或不夠的（例如以下會說明人口販運防制法第30條的修正是典型意願模式，但可資贊同也絕對必要）；更不是只要國家立法往典型能力模式移動，就會符合專家委員會對於國家消除私人強迫勞動在C29下的期待。最終，本節所要評估的，仍舊是我國法令與實務是否確實達成C29之下消除強迫勞動的任務。意願與能力模式的功能是理論座標，提出來主要是要幫助我們意識到，消除強迫勞動的作為，有藉積極作為處理背景

經濟因素的面向，而不能限於處罰違反意願的犯行，需要能力模式立法與意願模式立法相互的搭配。

一、臺灣在意願模式下的作為與欠缺

（一）對強迫勞動的禁止處罰

如前所述，ILO C29意願模式下國家作為的核心，是要求對強迫勞動之違犯，有足夠強度、獨立的處罰條款，及切實之執法。臺灣對私人間強迫勞動的制裁規定，散見於刑法、勞動基準法、與人口販運防制法，其發展大致呼應國際上對國家應介入哪種型態的私人間不自由勞動的理解，制裁的範圍逐漸擴大：1935年在中國制訂公布的刑法，主要處罰使人為奴隸或類似奴隸之犯行，學者指出係受國聯奴隸公約之影響¹⁹⁹。1984年的勞動基準法，規範最典型以直接強制侵害勞動自願性的違犯，立法理由註明是對C105的實踐²⁰⁰。至於2009年制定的人口販運防制法，則反映消除「現代奴隸」的人口販運倡議的國際壓力²⁰¹。

199 謝開平教授指出ROC政府在參與1926年廢奴公約後2年，舊刑法訂有與人為奴隸罪之規定。謝開平，檢視我國販賣人口刑罰規定之演進，成大法學，18期，頁48（2009年）。不過，ROC政府禁奴的刑事草案似遠早於1926年。參1912年暫行新刑律之立法理由：「奴隸制度，違反人道，歐美各國，早已懸為厲禁，獨吾國蓄養僮婢，此風未戢……際此解放時代，對於蓄養奴隸之惡習，自有嚴禁之必要」。黃源盛，晚清民國刑法史料輯注（下冊），頁1001（2010年）。

200 勞動基準法（1984年制訂）第5條立法理由：「參照我國於民國四十八年一月二十三日（自由日）批准之國際勞工組織『廢止強迫勞工公約』規定訂定，以防止雇主利用非法方法強迫勞工工作。」立法院法律系統，勞動基準法法條沿革，<https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lawsingle?00460D8F93E300000000000000000000032000000007000000^01139109052200^00035002001>（非固定網址）[<https://perma.cc/457P-8PQT>]。

201 人口販運防制法係在美國國務院人口販運報告，自2005年起將臺灣評等為第二級的壓力下制訂。這在人口販運防制法的文獻上幾乎都會記上一筆，如高玉泉，人口販運防制法之立法缺失與修法方向——以聯合國相關規範為中心之檢視，台灣法學雜誌，246期，頁28（2014年）；謝開平（註199），頁81-82；王皇玉，人口販運與使人為奴隸罪，月旦刑事法評論，5期，頁15-17（2017年）；王正嘉，勞動者保護與勞動刑法之法理與檢討，國立中正大學法

在這三階段針對不自由勞動的刑事立法中，以下討論刑法第296條與勞動基準法第5條，此二規定都被實務認為過時，實效不彰²⁰²。至於人口販運防制法，因2023年之修法於本文寫作時，尚無實務可供觀察是否有效補充前二者，僅將於下文「肆、二、(一)」指出修法前之人口販運防制法規範功能未如預期。

1. 刑法使人為奴隸罪

首先，刑法第296條處罰使人為奴、或「居於類似奴隸之不自由地位」(下稱「類奴隸罪」)二種態樣，但實務上能發揮功能之處僅在類奴隸罪²⁰³。這是因為奴隸制度的核心是將人作為可交易的財產，剝奪權利，使人成為法律意義上的物²⁰⁴，從而強制榨取勞動

學集刊，38期，頁130-131(2013年)；羅國榮，由國際發展觀點論人口販運勞力剝削之刑事規範，國立中正大學法學集刊，56期，頁54(2017年)。

202 附帶一提，除刑事處罰外，對個別強迫勞動指標所涉的風險行為，如沒收身分證件與短付或不付薪資，就業服務法於2002年增訂禁止仲介違反求職人意思扣留證件(第40條第3款)，2018年增訂禁止仲介違反勞工意思扣留證件(第40條第1項第10款)，違者處6-30萬罰鍰；2002年增訂對曾經非法扣留外國人證件或財物之雇主中止引進(第54條第1項第8款)。另勞動基準法第22條第2項規定「工資應全額直接給付勞工」，違者處2-100萬罰鍰。惟勞動部未有相關申訴、勞動檢查與裁罰的統計，因此不確定實務執行確實與否。現實似不容樂觀，因就證件，迄今勞動部仍允許雇主經移工同意即可保管移工之證件，參行政院勞工委員會，勞職外字第0920202991號函，<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=證件%26外勞&cnt=9&now=1&lnabndn=1&recordno=1> [<https://perma.cc/TW9Z-8NUY>]。而就薪資，過去法令曾允許雇主在移工「同意」下，得強制移工「儲蓄」高達30%之薪資，至移工返國始返還，參行政院勞工委員會，(87)台勞職外字第041329號書函，<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&keyword=預扣&cnt=8&now=1&lnabndn=1&recordno=7> [<https://perma.cc/GH68-CGLL>]。雖然主管機關指出這不是讓雇主「防逃」，而為了防止「外國人不正當經濟行為」，但說理毫無可信度，並充斥家父長姿態。現在雖然不再允許雇主「幫儲蓄」，但法院對於雇主短付薪資的行為易於認為是契約糾紛，而非強迫勞動或人口販運中的不法手段(詳「肆、二、(一)」)。

203 王皇玉(註201)，頁11。

204 奴隸公約的定義：“Slavery is the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised.” Slavery, Servitude, Forced Labour and Similar Institutions and Practices Convention of 1926 art. 1.

但「類似奴隸」又是什麼？這往往取決於現代人對奴隸處境的想像。學界主流見解認為是不人道對待，剝奪自由，使被害人失去人性尊嚴的實力支配²⁰⁶。法院較穩定的見解是身體自由全面受控、往往伴隨大量暴力虐待與傷害，並持續一段時間²⁰⁷。注意到對法院而言，身體控制與凌虐必須持續且嚴重，但是勞力榨取卻未必必要。如夫對外籍配偶長期禁錮虐待²⁰⁸、幫派份子對被害人私行拘禁

208 臺灣臺中地方法院93年度矚訴字第1號刑事判決之行為人長期拘禁被害人，以繩索細綁被害人雙手雙腳，僅於用餐、洗澡、上廁所鬆綁，限制被害人與外界聯絡，不供給基本日常生活所需與飲食，甚至供給酸敗食物，令其跪著吃飯，並以木棍、刀片、針、橡皮筋傷害被害人等。

加諸體罰²⁰⁹，殘暴不堪但未令被害人勞動，仍構成類奴隸罪。相對地，虛偽結婚以引進移工之（假）配偶²¹⁰與雇主²¹¹，儘管有控制移工行動、工時長、低薪或無薪、偶有語言肢體暴力、甚至利用權勢性交之實，均與強迫勞動指標若合符節，法院仍考量剝削與整體自由受拘束的程度，認定不構成類奴隸罪。實則，奴隸是一種不自由勞動的生產模式，卻未必總是發生大量身體凌虐²¹²。實務傾向將類似奴隸的處境理解成不人道禁錮凌虐，反而遠離了奴隸罪制裁不自由勞動的性質²¹³；加之法院在奴隸想像下，設定很高的身體控制與凌虐門檻，亦使其不適用於防制不那麼極端的強迫勞動案件。

2. 勞動基準法強迫勞動禁止

刑法使人為奴隸罪既然適用有限，則在2023年全文修正之人口販運防制法前²¹⁴，勞動基準法第5條「雇主不得以強暴、脅迫、拘禁或其他非法之方法，強制勞工從事勞動」，搭配第75條罰則，即是我國專門針對強迫勞動的主要刑事規範。它承襲刑法第304條強制罪的規範方式²¹⁵，反映出典型意願模式的立法，亦即關注身體與

209 臺灣苗栗地方法院99年度訴字第502號刑事判決之行為人拘禁被害人，限制被害人1天僅能食用1餐，強加體罰（半蹲、趴地面做拱橋、洗戰鬥澡），以球棒毆打被害人等。

210 臺灣臺中地方法院98年度易字第1346號刑事判決，檢方指控假結婚集團中之假丈夫有販賣人口及使人為類似奴隸犯行，法院認定行為人引進印尼籍女子來臺，派遣至雇主家從事勞役，從中剋扣薪資，但這是否已達人口販賣，使印尼籍女子處於物品的地位，仍有不明。

211 臺灣新北地方法院101年度侵訴字第36號刑事判決，本件一審認定：越南籍被害人藉虛偽結婚在臺灣小吃店工作，5年未獲薪資、受雇主監管照護、長工時、偶有責罵，雇主並與之權勢性交。二審臺灣高等法院102年度侵上訴字第15號刑事判決則認定，被害人係已婚雇主的妻，因此亦不構成權勢性交。本文重點在於一審認定事實下的法律判斷。

212 吳宗謀，奴隸是什麼東西？，歷史學柑仔店，2021年3月22日，<https://kamatiam.org/奴隸是什麼東西？/> [<https://perma.cc/BZ2W-LA9B>]。

213 類似見解：王皇玉（註201），頁14。

214 人口販運防制法雖在2009年制訂，但在2023年全文修正之前，並無針對違反意願勞動（無論是否構成剝削）的獨立處罰規定。

215 在逐條討論中立法委員明確指出「強暴、脅迫」用語沿用刑法第304條的規範

心理的直接暴力對於自願性的傷害，看似某程度回應C29第25條有關應以刑法制裁強迫勞動行為的要求，但實際上卻是具文。

一則是制定時，主事勞動官員對立法院聯席委員會中，對正在認真討論刑度恰當與否的眾立法委員表示，第5條立法原意是「政治性重於實質性」，因為只有「共產主義國家是強迫勞工勞動，沒有自由」²¹⁶。這不僅是對於國家強迫勞動（所謂共產國家之違犯）與私人間強迫勞動（勞動基準法第5條所欲應對的狀況）的混淆，也凸顯政府提案本意，僅視強迫勞動刑罰為冷戰時「非共產國家」自我標榜為自由國家的政治妝點，不必認真。

同樣透露勞動基準法第5條政治表態意味的是立法理由，其載明本條「參照我國於民國四十八年一月二十三日（自由日）批准之國際勞工組織『廢止強迫勞工公約』規定訂定」²¹⁷（強調為筆者所加）。「123自由日」是中華民國政府歡迎韓戰後有些中國戰俘選擇遣返至所謂「自由中國」，而非回到共產中國的反共宣傳節日²¹⁸。因此特意標明在「自由日」批准C105，反映了批准C105是冷戰下藉表彰勞動自由來反共的政治表態，勞動基準法第5條的出現，也是在冷戰末期延續同一邏輯。如同使人為奴隸罪往往被認為與現代社會不再相干，勞動基準法強迫勞動在制定之初即被認為與「非共產」之吾國不相干，冷戰後更無問津必要。

方式，是第304條的特別規定。立法院公報，73卷53期，頁5-11，本院內政、經濟、司法三委員會報告併案審查行政院函請審議「勞動基準法草案」暨「勞動基準法草案增加及修正部分條文草案」案，江鵬堅、張俊雄委員發言（1984年）。

216 內政部勞工司湯蘭瑞司長於1984年6月2日於內政、經濟、司法聯席委員會之發言，立法院公報，73卷65期，頁8，湯蘭瑞司長發言（1984年）。王正嘉（註201），頁116-117亦提及此發言。

217 參註200。

218 周琇環，接運韓戰反共義士來臺之研究（1950-1954），國史館館刊，28期，頁139、143-146（2011年）。

除了立法動機，作為專門防制強迫勞動的基礎規定，其適用範圍卻排除大量的勞工：因勞動基準法沒有普遍適用，以及條文開頭規定為「雇主不得……」，因此只有僱傭契約下、受雇主強迫、並為勞動基準法所涵蓋的勞工，才在保護之列²¹⁹。由第三人（如仲介、雇主親友）所施加的強迫勞動，不受該勞動刑法所涵蓋；而不適用勞動基準法的行業（如家庭看護），有可能亦不受其保護，再次反映本條並被不期望真正負起防制強迫勞動的基礎功能。

衡諸現實發展，其表態性質亦反映在執行上：勞動基準法第5條的強迫要件雖比類奴隸罪明確，案件卻更為罕見²²⁰，在實務上幾無意義。故無論從規範及執行面，ILO C29要求對強迫勞動犯行有獨立、足夠、有效之刑事制裁，至少2024年之前臺灣不能說已做到。未來人口販運防制法，執法上是否確實改善勞動基準法第5條的具文狀態，仍有待觀察。

最後，一個值得思考（但仍開放）的疑慮是關於，勞動基準法第5條係沿用刑法強制罪的典型立法方式制定²²¹，可是強制罪式立法，是否是適合對抗強迫勞動的刑事工具？問題的癥結在於，強制

219 類似批評，羅國榮（註201），頁42。

220 截至2024年2月20日止，筆者以勞動基準法第75條為關鍵字，搜尋司法院裁判書系統中所有地方法院刑事判決，去除自訴案件，留下案由相關者（「違反勞動基準法」、「勞動基準法」、「違反人口販運防制法」、「販賣人口」），僅餘10件，檢視內文僅有2件論及勞動基準法第5條犯行，最後只有1件（臺灣高雄地方法院97年度審簡字第1309號刑事判決）是雇主違反勞動基準法第5條（判處被告拘役參拾日，但無從知悉犯罪事實，因檢察官聲請簡易判決處刑，但系統中無本件之起訴書）。相對地，以刑法第296條和奴隸為關鍵字，搜尋所有地方法院公訴案件的判決，留下案由相關者（「妨礙自由」、「妨礙性自主」、「違反就業服務法」、「使人為奴隸罪」、「殺人未遂」），檢視內文有11件論及刑法第296條犯行，最後並有4件判處有罪。

221 勞動基準法第5條遭批評所涵蓋的手段太狹隘，參如徐國淦，從國際核心勞動基準探討我國勞動人權保障，台灣勞工季刊，39期，頁12（2014年），但在人口販運防制法第31條擴增涵蓋手段態樣後，應獲得相當解決。然而人口販運防制法第31條和勞動基準法第5條一樣是妨礙自由模式之立法，所以目前討論的問題仍有適用。

罪對於何謂刑法上可罰的不法強制手段之判斷，須考慮社會相當性²²²，而有些帶有強迫勞動疑慮的手段，在社會相當性的判斷中，可能會受到容許。

例如雇主對移工提出長工時要求或從事危險任務，不配合將予以解僱，或對無證移工表示將提出檢舉，並指出隨之面臨遣返的可能。解聘在特定要件下是合法的，對無證移工的檢舉不僅合法，更是勞動部以獎金鼓勵、應對無證移工的手段²²³，這些「合法惡害通知」，在妨礙自由的判斷上可能被認為不具違法性²²⁴；或國家正當執法應優先，被檢舉者（無證移工）本需忍受法律義務帶來的不自由²²⁵。然而，消除強迫勞動的邏輯卻是，移工的法律地位或經濟脆弱處境，不應被利用來使其忍耐惡劣工作條件與剝削，因此以檢舉、解僱與遣返為威脅使其留在低劣工作環境應構成強迫勞動。

沿用強制罪的立法型態，再次是古典意願模式的表現。若在實務運用中，強制罪式思維無法將具有強迫勞動疑慮的手段入罪，這未必是刑法社會相當性理論的缺陷，而是說明了強迫勞動的高風險

222 參如許恒達，論合法／不作為惡害通知的可罰界限——以強制罪、強制性交罪及恐嚇取財罪為中心，台灣法律人，25期，頁8-9（2023年）。社會相當性的實務見解參如臺灣高等法院111年度上訴字第2282號刑事判決。

223 民眾檢舉違反就業服務法相關規定獎勵金支給要點及附表，檢舉許可外工作之移工每位2,000元、檢舉失聯移工1-3位5,000元，10人以上最高2萬元。

224 不同見解參馬躍中，我國勞動刑法的現狀與未來——兼論德國勞動刑法，國立中正大學法學集刊，38期，頁172-173（2013年）。馬躍中教授主張勞動基準法（現行人口販運防制法第31條亦同）因加入「拘禁」手段，故所要求的強迫程度高於刑法強制罪，因此雇主利用無證移工的脆弱環境，不給予相當報酬或要求從事危險工作，不構成勞動基準法第5條的強迫。筆者以為，僅因法條將拘禁手段納入規範，就推論脅迫也要達到如拘禁一般的強度才能成罪，似乎並無基礎，但如馬躍中教授見解亦反映實務走向，本文所舉例子就算會構成強制罪也不構成勞動基準法上之強迫勞動，此立法政策選擇，從C29第25條（足夠、獨立的刑事制裁）要求來看，乃值得商榷。

225 黃榮堅，悲情姊妹花，月旦法學雜誌，10期，頁47（1996年）。其主張常被認為是有力的少數說。

行為需要獨立規範。這也意謂國境管制執法的優先性必須適度退讓，並節制雇主之管理特權，以降低強迫勞動之風險。

勞動基準法第5條的重大漏洞，直到2023年（勞動基準法制定後近40年）才由人口販運防制法修正之第30條第1項「以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、詐術、催眠術或其他相類之方法，使人提供勞務者」（2024年1月1日施行）所填補²²⁶，不再限於有勞動基準法適用之行業、在僱傭關係中、遭到雇主本人違反其勞動意願之勞工，始有適用，成為我國處罰強迫勞動的基本規定，也才真正開始確定對易於遭到強迫勞動，卻遭排除在勞動基準法保護外之家戶移工或境外聘僱漁工，提供最基本的刑事保護，而有符合C29第25條（參前文「參、二、（二）、1.」）所要求之強迫勞動制裁規定。至於其實際執行，是否確切有效追訴相關犯行，則仍待觀察。

（二）國家對移工轉職自由之限制

ILO所定義的非強迫勞動，自願性須貫穿工作的所有階段，包括離職與否，因此轉換工作的可能，是維持自願性最重要的制度條件之一（前文「參、二、（二）、2.」），亦是勞工抵制不理想工作條件的最後手段²²⁷。對工作流動性，如前所述，專家委員會要求移工得終止契約之法定事由，須能涵蓋所有應予終止情形；移工應得在相當期間預告後單方離職，且得在居留期間內合理轉職而非被迫立即離境。這些在意願模式下避免強迫勞動的基本制度要求，臺灣亦有相當改善空間。

226 2009年之人口販運防制法第32條第1項處罰強制剝削勞力罪，雖然其立法理由提及這是對勞動基準法強迫勞動處罰的填補，立法院公報，98卷5期，頁71-72（2009年）。但因為其要件是「使人從事勞動與報酬顯不相當之工作」而非提供勞務，所以並沒有真正填補到。

227 藍佩嘉（註61），頁120；劉梅君，「廉價外勞」論述的政治經濟學批判，台灣社會研究季刊，38期，頁78（2000年）。

姑不論換工作之實際困難，臺灣法律明文加諸移工的轉職限制至少有3個層面：第一，移工雖然從事繼續性工作，但僱傭契約一律強制為定期契約，最長3年²²⁸。第二，在定期契約期間內，須有法定事由始得進入轉換程序²²⁹。第三，移工在契約期間內轉換雇主或工作，原則上不得跨業轉換²³⁰。轉換程序是與時間和經濟壓力賽跑的過程：在轉換程序期間內不得工作，並須在60日內（或經勞動部核准展延60日）有合於資格的新雇主接續聘僱²³¹，否則由原雇主負責為移工辦理離境出國。申言之：

1. 定期契約內限制流動

首先，定期契約強制中斷繼續性工作，增加就業脆弱性與被仲介不當收費的可能，自不待言。強制換約的節點越多，移工越必須刻意柔順確保順利續約，實質降低移工團結權行使可能²³²，因為對有異見之移工，雇主只要期滿不予續約，即足以合法阻止移工團結²³³。除了明顯增加脆弱性外，定期契約也是限制移工流動的機制，因為移工在契約期間內進入轉換程序與跨業轉換，比契約期滿

228 就業服務法第46條第3項規定聘僱移工「以定期契約為限；其未定期者，以聘僱許可之期限為勞動契約之期限」；第52條第2項規定移工聘僱「許可期間最長為三年」。

229 就業服務法第59條第1項規定，移工有下列情事，經勞動部核准得轉換雇主「一、雇主或被看護者死亡或移民者。二、船舶被扣押、沈沒或修繕而無法繼續作業者。三、雇主關廠、歇業或不依勞動契約給付工作報酬經終止勞動契約者。四、其他不可歸責於受聘僱外國人之事由者。」

230 外國人受聘僱從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之轉換雇主或工作程序準則第8條第1項規定，移工轉換工作「以原從事同一工作類別為限」。

231 外國人受聘僱從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之轉換雇主或工作程序準則第11條第1項。

232 林良榮，論外國人勞工（移工）團結權之行使與保護——ILO規範基礎、工會組織實務與團結政策，交大法學評論，勞動法特刊，頁263（2020年）。

233 邱羽凡教授於〈過水有痕：「外勞」30年／MENT 20年國際研討會〉口頭發言。邱羽凡，移工制度研究進行式，過水有痕：「外勞」30年／MENT 20年國際研討會，台灣移工聯盟主辦（2023年12月16日）。

後轉換，受到更嚴格限制²³⁴。這些契約期間內的轉職限制，更使定期契約雖然增加脆弱性，「會期滿」卻看來像是對移工有些「好處」、不可或缺。

2. 聘僱許可未到期之轉換須有法定事由及官方核准

其次，關於法定事由：在契約期間內，移工原則上沒有單方終止契約的權利²³⁵，除非有不可歸責於移工、雇主無法繼續聘僱的法定事由（詳註229），並經勞動部核准後，始得進入轉換雇主之程序。法定事由包含「其他不可歸責於受聘僱外國人之事由」之概括條款，廣泛包括雇主與移工合意轉換及雇主違法或違約的情況。表面上，這個條款允許雇主與移工合意轉換的可能，且文字彈性讓專家委員會所擔憂的法定轉換事由太窄的問題，在臺灣比較不會發生，能涵蓋移工可能受到的各型態惡待而准其轉換，例如性騷擾（違反性別平等工作法第12條）、指派許可外工作（違反就業服務法第57條）、不付加班費（違反勞動基準法第24條）等。

但實際上，「合意」轉換即指雇主對移工轉出與否享有否決權²³⁶，制度上並有許多降低雇主合意意願（且高度依賴私人仲介）的理由。例如雇主在同意移工轉出後，聘僱許可雖然已被廢止，仍須負擔移工之生活照顧義務，直到新雇主接續聘僱，如無人接續聘僱並應負責令移工出國，否則面臨罰款²³⁷。又如雇主同意移工轉出

234 比較外國人受聘僱從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之轉換雇主或工作程序準則第8條（非期滿轉換）；「外國人辦理轉換登記，以原從事同一工作類別為限」與同準則第25條第1項：「期滿轉換之外國人辦理轉換雇主或工作，不以原從事之同一工作類別為限。」

235 此限制迭經法學者指為違憲，如：王韻茹，從憲法觀點論移工權益的平等保障——以限制轉換雇主規定為例，法律扶助與社會，3期，頁9（2019年）；林佳和（註27），頁218-219。

236 顧玉玲（註61），頁97。

237 跨國勞動力管理組，就服法第58條修正今生效 大幅縮短移工失聯遞補等待期，勞動力發展署，2023年5月12日，https://www.wda.gov.tw/News_Content.aspx?n=31&s=4279 [<https://perma.cc/D8TD-ZS58>]。

後，並不是一定能聘新移工來遞補人力需求，僅有家庭看護移工之雇主，在同意轉出之移工獲新雇主接續聘僱、或移工在聘僱許可因轉出而廢止1個月後仍未有新雇主接續聘僱，且此時原聘僱許可所餘期間仍逾6個月，方得申請遞補²³⁸；即便能遞補也有數週空窗²³⁹，產業移工之雇主則無法申請遞補²⁴⁰，因此有人力需求的雇主，欠缺同意移工轉出的動機。

另一方面，若無從獲得合意，移工須基於雇主違法、違約之事由始得受核准轉出，此時除面對舉證困難²⁴¹，移工能指摘雇主違法違約的前提，是有勞動法令的樓地板、或最不濟有書面締約可供參酌。這使得不受勞動基準法保護、也往往沒有書面簽約的家戶移工²⁴²，在受到惡劣的勞動條件時，根本無從指摘起。所以勞動保護的孱弱，所影響的並不只是工作條件，在目前轉換制度下，還會使最不受保護的勞工亦最難流動。

3. 跨業轉換的緊縮

最後，關於移工轉出的跨業轉換（即契約中途換雇主時，能跨到其他行業求職）原於2008年開放，當時外國人受聘僱從事就業服

238 就業服務法第58條第2項第3款與第3項。2023年5月10日新增允許家庭看護移工的雇主在同意轉出而廢聘後1個月即可申請遞補。

239 「要找下一個幫手……至少5週空窗期，在一個需要直接人手來照護的家庭……是一個很大的困擾，所以為何會有雇主不簽名」。蔡明學、劉黃麗娟，蔡明學發言，與談紀錄，交大法學評論，勞動法特刊，頁87（2020年）。

240 外國人受聘僱從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之轉換雇主或工作程序準則第21條：「接續聘僱之雇主或原雇主依本準則接續聘僱或轉出外國人時，不得以同一外國人名額，同時或先後簽署雙方或三方合意接續聘僱證明文件，或至公立就業服務機構接續聘僱或轉出外國人」。

241 邱羽凡、宋庭語，移工自由轉換雇主之限制規範與檢討，交大法學評論，勞動法特刊，頁25-26，註34、35（2020年）。

242 黃姿華、劉梅君，黃姿華發言，與談紀錄，交大法學評論，勞動法特刊，頁125（2020年）。黃姿華指出在實務上，移工第一次入國必須有勞動契約，但續聘或轉換則沒有強制簽訂，許多移工與雇主完全沒有意識到契約的存在，以及有最低標準的勞動規範需要遵守。

務法第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之轉換雇主或工作程序準則（下稱轉換準則）雖有移工轉換工作「以原從事行業之同一工作類別為限」之原則規定，但是不同工作類別而合於條件的雇主得接續聘僱²⁴³。2021年因Covid-19疫情移工引進人數減少，製造業有更多工缺，勞動條件最差的家戶移工類別，更不易招聘到移工，勞動部在雇主壓力下著手緊縮跨業轉換的管道，阻擋家戶移工在3年聘僱期間內轉換為廠工，其在總說明中露骨表示移工不流動、不加薪是雇主的權益，為避免雇主權益受損而要落實不跨業流動原則²⁴⁴。

作法上是讓與移工原工作同一類別的雇主，有優先順位接續聘用²⁴⁵，亦即家戶移工轉出，只要有家戶移工雇主登記接續聘用，廠工雇主順位就會殿後。而為了確保轉出的家戶移工不能自行接洽廠工雇主合意聘用，原本允許勞雇雙方或三方合意轉出，跨業承接移工的管道一併關閉²⁴⁶，新雇主一律必須在公立就業服務中心登記，

243 行政院勞工委員會2008年2月27日勞職審字第0970503164號令修正發布之外國人受聘僱從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之轉換雇主或工作程序準則第7條。

244 「部分外國人以怠工要求雇主同意轉換雇主或工作，或要求雇主提高薪資，已嚴重影響雇主權益」，跨國勞動力管理組，外國人受聘僱從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之轉換雇主或工作程序準則部分條文及第十三條附表一、第二十二條附表二修正總說明，勞動部勞動力發展署，2021年8月27日，<https://ws.wda.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMjk5L3JlbGZpbGUvNzc2OS8xMzMzMzMvMWFjYWQ5YjUtNGVlNy00MzVjLWE5YzEtNmM4ZDZlJmJyYmRiLnBkZg%3d%3d&n=MTEwMDgyNy30vYnmj5vmupbliYfkv67mraPmop3mlofnuL3oqqmmml4oZmluYWwt5aSWKS5wZGY%3d> [https://perma.cc/AXT4-5EU2]。

245 外國人受聘僱從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之轉換雇主或工作程序準則第7條第1項第1、2款。

246 跨國勞動力管理組，「外國人受聘僱從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款規定工作之轉換雇主或工作程序準則」修正問答集，勞動部勞動力發展署，2021年8月27日訂定，2021年9月13日修改，<https://nws.wda.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMS9SZWxGaWxILzEwMjk0LzE0MzYvMTEwMDkxMy0o56ysMuasoSnovYnmj5vmupbliYfkv67mraPlly%2fnrZTpm4YoZmluYWwpLnBkZg%3d%3d&n=MTEwMDkxMy0o56ysMuasoSnovYnmj5vm>

在連續14天都沒有同類別的雇主登記接續聘僱，才能由不同工作類別的雇主聘僱²⁴⁷。反之只要有一個同工作類別雇主登記，14天會重新起算，如果移工不願意受同一工作類別的雇主聘僱，就需再等是否會有下一個連續14天沒有同工作類別雇主登記，而可以由後順位的不同工作類別雇主接續聘僱²⁴⁸。移工若未在60天（或再展延60天）內與新雇主合意接續聘僱，就必須返國。以此邏輯，勞動部大言不慚地在修正問答中宣稱其並未禁止移工跨業轉換，甚且強調「移工仍可自行選擇新雇主」²⁴⁹——只是如果一直媒合不成而得離境那是自找的。這是意願模式修辭的極致運用：家戶移工實質上失去跨業轉換的管道，正因為國家知道他們須在120天內自願屈服。

ILO公平招募一般原則第12點再次重申勞工離職換工作不需要雇主同意²⁵⁰。離職只是很低程度的勞動保護，因為離職無法確保勞動條件的提升，但是消除強迫勞動的歷史經驗所凸顯的即是，為何不能沒有此種保護²⁵¹，以及這麼低度的、屬於意願模式核心的保護，實際上又如何難以企及——正如臺灣移工制度所示。在綁定雇主的定期契約下，法令不允許移工單方預告離職，產業移工難以獲得合意轉出，社福移工若合意轉出也無法跨業轉換工作，勞動主管機關並將移工受法令箝制下的勞動不自由，視為是雇主應受保護之制度利益。

upbliYfkv67mraPliY%2fnrZTpm4YoZmluYWwpLnBkZg%3d%3d [https://perma.cc/5GHJ-826B]。

247 勞動部，勞動發管字第11005137701號令，<https://ws.wda.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMjk5L3JlbGZpbGUvNzc2OS8xMzMzMzMvYzZhMTQwMWYtNDE2YS00MzFkLTg2YTUtYjc4ZjBmNjM0ZDliLnBkZg%3d%3d&n=55m85biD5LukMTEwMDUxMzc3MDEucGRm> [https://perma.cc/C6X5-4ZUG]。

248 外國人受聘僱從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之轉換雇主或工作程序準則第10條第7項。

249 跨國勞動力管理組（註246）。

250 ILO, *supra* note 176, at 14.

251 Katherine V.W. Stone, *Revisiting the At-Will Employment Doctrine: Imposed Terms, Implied Terms, and the Normative World of the Workplace*, 36 INDUS. L.J. 84, 86 (2007).

二、臺灣在能力模式下的作為與欠缺

能力模式進一步認為國家應介入處理若干經濟危脆議題，前已述及ILO在人口販運防制影響下，關注剝削和脆弱處境的應對，下文因此選取仲介收費管制與勞動法令的欠缺作為切入點，藉此指出臺灣實務對於能力模式取徑的抗拒。

(一) 債務約束與仲介收費

債務約束通常是無資產債務人需因應大筆開銷而借貸，而以未來勞務作為債務擔保。但當債務人大部分勞動所得用於償債，只能獲取少部分薪資，為支應接下來的必要開銷，可能又引發新的債務，進入惡性循環²⁵²。跨國移工為了獲取海外工作機會與支付跨國遷移的費用，被認為是新型態債務約束的典型成因²⁵³。債務約束中，法律上的債主與雇主未必是同一人，但雇主仍從勞工的沉重債務獲得對移工高度的控制。適當控制私人仲介業的收費與管理，因此是降低債務約束的重要工作。

1. 行政管理

為衡量臺灣移工所付的跨國費用高低，本文與2個數字相比：一是國際組織的期待：世界銀行研究小組對移工跨國費用所設目標為不超過1個月薪資²⁵⁴；二是鄰近國家的現實：ILO調查馬來西亞之越南籍移工付費，移工跨國費用平均1,370美元，約是越南移工

252 SMITA PREMCHANDER, V. PRAMEELA & M. CHIDAMBARANATHAN, PREVENTION AND ELIMINATION OF BONDED LABOUR: THE POTENTIAL AND LIMITS OF MICROFINANCE-LED APPROACHES, at iii (2014), https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_334875/lang--en/index.htm.

253 *Id.* at 2.

254 NILIM BARUAH, HEIKE LAUTENSCHLAGER & PE RESEARCH, WORKER-PAID MIGRATION COSTS IN THE VIET NAM-MALAYSIA CORRIDOR 6 (Dec. 26, 2018), http://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_657134/lang--en/index.htm.

在馬來西亞3.21個月之薪資²⁵⁵。相較之下，臺灣之移工工作機會收費高昂，學者藍佩嘉與簡永達的調查顯示，在傳統產業招募越南移工之市場裡，移工所支付的仲介費用在5至6千美元之間²⁵⁶（不包括入境後的每月仲介服務費，3年合計新臺幣6萬元，約1,900美元，詳下），這大約是事業面移工在臺灣5-6個月之薪資²⁵⁷。

對於高收費，臺灣的管理方式，第一是針對仲介收費項目與標準訂定上限：勞動部規定仲介引進移工僅得收取服務費，依移工年資第1年每月上限1,800元、第2年每月上限1,700元、第3年起每月上限1,500²⁵⁸。為貫徹「服務」費之性質，勞動部強調有服務事實始得收取，且不得預先收取²⁵⁹。但是事實上勞動部並未針對何種事實能稱為服務、各能收多少費用有過規定，更不核實調查服務事實之證據有無，服務費在實務上是總價為3年6萬元之仲介費的分期付款²⁶⁰。

在法令上，仲介雖僅得向雇主收取移工1個月薪資以下之登記費及介紹費，與每年每人2,000元以下之服務費²⁶¹，不得向移工收

255 *Id.* at 13.

256 藍佩嘉、簡永達（註82），頁19。藍佩嘉與簡永達將臺灣仲介市場分為三個區塊：以招募菲律賓移工為主的電子業、招募印尼移工為主的家庭看護與招募越南移工為主的傳統產業。其指出前二者因供應鏈管理的興起、輸出國政府介入與人權基礎建設的強化，雇主必須負擔招募成本，移工所負擔比例下降，但傳統產業招募越南移工部分的仲介費卻長久以來居高不下。

257 依勞動部調查，2022年6月事業面移工總薪資平均為新臺幣3萬2,303元（其中經常性薪資為2萬6,066元，加班費5,619元），因此筆者粗略以月薪1,000美元來衡量跨國遷徙費用的高低。勞動部，111年移工管理及運用調查報告，頁9（2022年）。

258 服務費政策即是在2001年仲介費飆升到約新臺幣29萬元的背景下訂定，所以對業界而言，服務費就是實質的仲介費。陳炯志，從臺韓移工聘僱歷史思索臺灣直接聘僱制度的改善之道，交大法學評論，勞動法特刊，頁201（2020年）（仲介市場發展背景）。

259 跨國勞動力管理組，仲介公司收取移工服務費注意三條件，勞動部勞動力發展署，2021年6月23日，https://www.wda.gov.tw/News_Content.aspx?n=31&s=3936 [<https://perma.cc/QZS8-NGBD>]。

260 顧玉玲（註61），頁102。

261 私立就業服務機構收費項目及金額標準（下稱仲介收費標準）第3條第1項。

取仲介費與「買工費」(移工轉出或期滿後換工作的媒合費用)，但實際上仲介未必向雇主收費，而向移工收取仲介費及買工費，是業界普遍現象²⁶²。就此執行問題，勞動部的作為輕省：發新聞稿重申違法收費的仲介依就業服務法可處15至20倍之罰鍰、1年以下停業或不予換證，呼籲移工檢具事證檢舉²⁶³。但對於有可能提供私人仲介以外之媒合管道的積極作為，即官方直聘中心，卻在效能不彰的評估下縮編²⁶⁴。

臺灣的第二個管理方式是試圖透明化海外收費與薪資結構。勞動部要求移工簽署〈外國人入國工作費用及工資切結書〉(下稱切結書)，其載明海外仲介收費、規費等，及入國前的債務、未來薪資和扣除項目，並經移工本國主管機關公證後，用以申請簽證，再攜帶至臺灣供雇主申請聘僱許可²⁶⁵，雖本是保護移工的措施，若移工抵臺無法出示認證後的切結書則會被遣返²⁶⁶。又切結書上「規定」仲介費及借款應由移工輸出國查證²⁶⁷，但如何能靠切結書記載，賦

262 邱羽凡、宋庭語，(註241)，頁41，註71。(訪談記錄：「仲介公司彼此間壁壘分明，若移工要去另一家有工作機會的仲介公司工作，則需要『買賣』……倘若移工自行先找到雇主，然與該雇主配合者為另一個仲介，此時是移工比較想要這份工作，買工費通常會轉嫁到移工身上」)；桃園市群眾服務協會移工服務暨庇護中心主任汪英達指出，買工費在原就業服務法第52條移工3年契約期滿需出境至少1日的規定廢除後，變得普遍及金額陡升，以往1萬元買工費已是天價，「可是現在如果聽到新仲介對菲律賓移工收1萬元買工費，我們甚至會錯亂的會覺得這個仲介是佛心來的，『居然』只收1萬元」。汪英達、劉黃麗娟，汪英達發言，與談紀錄，交大法學評論，勞動法特刊，頁190(2020年)。

263 跨國勞動力管理組，移工遭收買工費係屬違法 勞動部將積極查處，勞動部勞動力發展署，2020年4月5日，https://www.wda.gov.tw/News_Content.aspx?n=30&s=2198 [<https://perma.cc/AQG4-QWJY>]。

264 陳炯志(註258)，頁208-209。

265 雇主聘僱外國人許可及管理辦法第32條第1項第5款及第34條第4項。

266 行政院勞工委員會，(90)台勞職外字第0225169號函，<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?searchmode=global&datatype=etype&no=FE111604&keyword=其他> [<https://perma.cc/QMB5-GQL4>]。

267 2022年8月10日勞動發管字第11105118071號令修正之切結書，得於以下網址下載：跨國勞動力管理組，外國人入國工作費用及工資切結書(中、中英、中

予輸出國義務，實有可疑。在司法實務上，法官認定輸出國有查證義務，反而成了仲介不實記載沒有刑事責任的理由之一（詳下）。

2. 刑事制裁

在以上二種紙面行政管理外，人口販運防制法處罰「利用不當債務約束或他人不能、不知或難以求助之處境，使人從事勞動與報酬顯不相當之工作」（2023年6月14日修正前之第32條第2項規定，下稱舊人口販運防制法）²⁶⁸，似乎可能用以應對債務約束或脆弱情境所致之剝削。特別是考慮到人口販運防制法制定的主要現實理由之一，來自移工承受高仲介費與高負債，臺灣因此被美國點名為人口販運國，面臨其貿易制裁，政府乃在壓力下完成立法²⁶⁹。然而，

印、中越、中泰），111年8月10日生效，勞動部勞動力發展署，2022年8月10日，https://www.wda.gov.tw/News_Content.aspx?n=66&s=11114 [<https://perma.cc/9L6Q-V3JF>]。

本文參考之外國人入國工作費用及工資切結書中英版之下載網址為：<https://ws.wda.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMjk5L3JlbGZpbGUvODc4OC8xNDYxNjYvMjRjZWUwODUtZTc3NS00NDc2LWE5MmEtYzQ4OWQzNGJjZDIyLnBkZg%3d%3d&n=MTEExMDgxMC3kuK3oi7Et5aSW5ZyL5Lq65YWI5ZyL5L2c6Lk755So5Y%2bK5bel6LOH5YiH57WQ5pu4LnBkZg%3d%3d> [<https://perma.cc/JQ6X-LBK9>]。

- ²⁶⁸ 2023年修法前之人口販運防制法第32條第2項，2023年修法後移列為第31條第2項。新法刑度不變，但構成要件有下列不同：(1)處罰範圍擴增（**粗體部分為新增**）：「利用不當債務約束、他人不能、不知或難以求助之處境、**扣留重要身分證明文件**，使人從事勞動與報酬顯不相當之工作或實行依我國法律有刑罰規定之行為者」。(2)修正第2條之「不當債務約束」定義：舊法為「指以內容或清償方式不確定或顯不合理之債務約束他人，使其從事性交易、提供勞務或摘取其器官，以履行或擔保債務之清償」，新法刪除「使其從事性交易、提供勞務或摘取其器官」用語。(3)增訂第2條「勞動與報酬顯不相當」之定義（由舊人口販運防制法施行細則第4條移列，並新增**粗體部分文字**）：「指綜合考量實際勞動所得報酬與其工時、工作內容、工作場所、工作環境等勞動條件，與相類工作之一般勞動條件相較顯不合理」。

上開修正值得贊同，但上開修正若適用於下文所討論的指標案件臺灣新竹地方法院100年度易字第258號刑事判決，對法院認定債務合理與否、報酬是否相當、及仲介責任鏈的方法與標準，是否有影響，判決結果是否不同，本文存疑。未來檢方是否願意再度費力查證起訴類似案件，更有待觀察。

- ²⁶⁹ 美國國務院人口販運報告2006年將臺灣列為第二級觀察名單，2007年列為第二級，都指出到臺灣工作的移工所支付的高額仲介費（高達8,000乃至14,000

法院實務否定仲介不法高額收費與高利放貸所致移工債務，構成上開舊人口販運防制法上不當債務約束剝削勞力之犯行，可說立法後並沒有真的回應到原本遭到國際譴責的現象²⁷⁰。

指標案件²⁷¹是臺灣新竹地方法院100年度易字第258號刑事判決（法官楊麗文）²⁷²與臺灣臺北地方法院102年度易字第599號刑事判決（法官余銘軒）²⁷³。二案情節類似，新竹地院判決不僅較早，且臺北地院判決和各自之上訴審判決，論理均和新竹地院判決高度雷同，因此新竹地院判決理由反映司法體系迄今對此類案件的看法，茲僅以新竹地院一案說明。

該案中，檢察官調查金流與訪談上百位菲律賓移工後²⁷⁴，認為仲介業者在臺灣、菲律賓端，各自成立仲介公司引進移工，同時經

美元）導致負債與強迫勞動。Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, *Country Narratives-Countries Q through Z, Trafficking in Persons Report*, U.S. DEPARTMENT OF STATE (June 12, 2007), <https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2007/82807.htm> [<https://perma.cc/FTJ4-QWRL>]; Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, *VI. Country Narratives-Countries Q through Z, Trafficking in Persons Report*, U.S. DEPARTMENT OF STATE (June 5, 2006), <https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2006/65990.htm> [<https://perma.cc/A939-QV9L>].

270 類似批評：羅國榮（註201），頁68-69。

271 本文以「債務約束+人口販運防制法」為關鍵字，搜尋司法院判決書裁判系統，截至2024年11月5日止，獲得地方法院層級之判決75則，其中事實態樣涉及仲介業者對移工提供貸款、收取超過法定利率之利息及超過法定之仲介費，經檢察官以舊人口販運防制法第32條第2項起訴者為此2案。

272 司法院裁判書系統，臺灣新竹地方法院100年度易字第258號刑事判決，2014年1月10日，<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=SCDM%2c100%2c易%2c258%2c20140110%2c1&ot=print> [<https://perma.cc/Y5KZ-JEF5>]。嗣經臺灣高等法院103年度上易字第636號刑事判決維持原判論（法官葉騰瑞、陳芃宇、彭政章）。

273 司法院裁判書系統，臺灣臺北地方法院102年度易字第599號刑事判決，2015年5月19日，<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPDM%2c102%2c易%2c599%2c20150519%2c1&ot=print> [<https://perma.cc/5M6C-5J8D>]。嗣經臺灣高等法院104年度上易字第1420號刑事判決（法官鄧振球、何信慶、郭雅美）維持原判。臺灣高等法院104年度上易字第1420號刑事判決並未寫入下文所批評之「甚至本外勞最低工資不脫勾也是仲介非法收費不應被課責」的理由。

274 簡永達，移工築起的地下社會：跨國勞動在臺灣，頁353（2023年）。

營財務公司貸款予移工，不法收費、貸款、招募，以前開不當債務約束之勞力剝削罪嫌起訴仲介業者。法院認定被告之仲介公司對菲律賓移工收取6至13萬披索之費用，違反菲律賓政府對仲介費之上限規定（即移工1個月薪資，當時約25,920披索）；又被告之財務公司所收取之年利率高達40%，亦高於菲律賓規定貸款予移工之利率不得超過年利率8%之規定。業者亦在切結書上登載未借款，以此不實文書辦理認證、簽證與聘僱許可；並要求移工簽具本票，移工還款有困難時即遭法院強制執行。有些移工指控被告仲介時宣傳之工作條件與所得水準與實情有落差、每月經扣款後所餘無法生活、有些移工指稱居住環境惡劣、並遭雇主代為強制儲蓄部分薪資，與「保管」護照等等。

以上事實有數個強迫勞動及人口販運指標的徵候，包括欺騙招募、惡劣生活條件之剝削、扣留證件薪資、人身行動控制、以及可能之債務約束，但本件判決無罪。法官對移工負債「自願」與選擇的認定，與其對業者經濟邏輯的體諒，形成強烈的對比。其深刻反映出意願模式邏輯在此類案件的影響。

一方面，儘管業者收費非法，而移工可能出於「無奈或自願、樂意或不樂意」²⁷⁵繳高額仲介費，但法官指出本案非涉不當債務、亦無心理拘束。移工本即知悉業者所收費用與利率，亦可選擇其他仲介與財務公司辦理、未受暴力強迫或欺騙，且所簽具之本票有中英文對照，不能以不知臺灣法律諉為不知（儘管並非所有菲律賓人均能閱讀英文）。又雇主雖強迫儲蓄與保管護照——典型的強迫勞動指標，但法院認為都有移工簽字同意，並可在要求後取回等等。也就是說，「自願」相當程度地影響法官對於人口販運要件的判斷²⁷⁶，移工自須承擔自願進入的債務與本票。

275 臺灣新竹地方法院100年度易字第258號刑事判決，1083行。

276 在本件判決之外，鄭智仁2017年對地方法院人口販運案件無罪判決所作的分

他方面，法官多次指出以人口販運罪處罰業者並「不公平」，體諒仲介業的商業邏輯「不得不」非法收費，對人口販運立法有所商榷並採限縮的解釋路徑。這包括法官認為所有仲介業者普遍違法超收仲介費，無從要求被告單獨守法，且被告超收程度符合市場行情，「企業在商言利，本即如此」²⁷⁷；仲介建立跨國遷移鏈，將所有可能利潤一網打盡「天經地義，原即無從厚非」²⁷⁸。業者雖以不實切結書申請認證，但法官認為菲律賓官方應查核文書實在與否，菲國官方既未盡責保護其國民，則課以我國仲介刑責並不公平。甚至連勞動基準法對移工最低工資的保護，法官也認為算是仲介業者向移工非法收費的「正當」理由：

若將勞工輸入國就外勞引進所設計與本國勞工最低工資相同之不脫勾處理造成本國企業為求降低成本不願再負擔其他費用所產生各種不利益，僅因被告等人在前端向菲律賓勞工收取超過該國政府規定之仲介費並貸以超過該國及我國政府規定最高年利率之利息，即將上開被告等人無力憾動[按：應為撼動之誤]之外勞引進制度或全球經濟走向所產生各種市場實際之供需狀況，徒以不當債務約束及勞務剝削為由，全令被告等人負擔，並不公平²⁷⁹。

對業者的經濟算盤體諒到了怪罪於勞動法令的程度——但法官能看見業者的經濟現實，何以不能看見移工的經濟現實呢？此種失衡的論理，在嗣後的判決裡卻仍被重述²⁸⁰。

析亦顯示，自願發生債務，是通常認為不構成不當債務約束的理由之一。鄭智仁，人口販運之判決分析——以地方法院判決為例，亞洲家庭暴力與性侵害期刊，13卷1期，頁69-70（2017年）。

277 臺灣新竹地方法院100年度易字第258號刑事判決，1195行。

278 臺灣新竹地方法院100年度易字第258號刑事判決，1497行。

279 臺灣新竹地方法院100年度易字第258號刑事判決，1432-1440行。

280 臺灣高等法院103年度上易字第636號刑事判決、臺灣臺北地方法院102年度易字第599號刑事判決。

本則判決亦凸顯ILO強迫勞動概念，對於不自由勞動，完全排除經濟危脆，是有代價的。本案法官轉引ILO專家委員會說「迫使勞工接受低薪的經濟限制本身」、「個人為維持生計，必須接受不理想的工作」，「不屬於[C29]公約規範範圍」²⁸¹，據此認定移工所受的經濟壓力，來自母國就業機會匱乏的窘迫，受此制約不是債務約束。姑不論這則引用可能的技術瑕疵²⁸²，確實大環境欠缺工作機會導致失業或工作不理想，不是強迫勞動。但必須注意到，ILO的實務發展也要求國家（包括司法在內）避免工作機會與經濟壓力的背景因素，被利用來更進一步地劣化勞動流動的可能性與條件，包括消除不法收費、避免與降低債務、遏止對經濟脆弱地位的利用。而這些作為，正是這則判決在肯定仲介商業模式正當性與移工債務自願性之餘，所未能實踐的。這也顯示ILO謹守古典意願模式，不將經濟危脆納入強迫概念，在實務上的負面效果是使國家機關昧於意願模式邏輯，以「自願」為由，而看不到能力模式所要應對的制度性經濟箝制問題。

281 完整引文如下：「聯合國國際勞工組織專家認為，迫使勞工接受低薪的經濟限制本身，不屬於公約規範範圍，愛爾蘭公會[按：應為工會之誤]指控，失業勞工被迫接受政府就業計畫中，低薪且不適當的工作，委員會對此表示：失業及高階工作機會稀少問題（亦即個人為維持生計，必須接受不理想的工作），通常不屬於公約規範範圍（See., Individual Direct Request by the Experts on the Application of Conventions and Recommendations Concerning Convention No.29, Forced Labour, 1930 Ireland, ILO, 2001，以上見法院辦理違反人口販運防制法相關案件參考手冊第123頁以下）」。臺灣新竹地方法院100年度易字第258號刑事判決，1472-1482行。截至2024年2月止，筆者查到有5個判決逐字引用這段文字，用以認定被告不構成債務約束的勞動剝削。

282 這段文字實際語出前註判決所引用之「法院辦理違反人口販運防制法相關案件參考手冊」第124頁註71，來源雖標示為ILO專家委員會2001年對愛爾蘭就C29提出的「個別直接要求」，惟筆者於ILO資料庫中並未查得該筆紀錄，不知是否誤植。又引用的脈絡亦可商榷，引文中ILO專家委員會所討論的問題是，申請失業救助須以參加政府就業計畫為前提，國家的此種就業要求，是否構成強迫勞動。但司法院手冊引來所欲處理的法律問題是，不當債務約束所致的強迫勞動，債主跟雇主是否必須是同一人。本案又引用來認定，移工因本國經濟困頓而到臺灣來工作，並非受迫或受債務約束，而是自願的選擇。此種引用不無脈絡跳躍之嫌疑，降低說理的價值。

為本段作結，這一波無罪判決後，據報導檢察官不再起訴類似案件²⁸³，國家對私人仲介業管理失能，且形同自甘為業者的討債公司²⁸⁴。能力模式下國家的任務終究在於管控招募過程的剝削，因此無論國家決定對於仲介非法收費高利放貸之行為，刑事處罰範圍界定到哪裡，重要的仍是必須有管理能力，有效降低仲介加劇移工之經濟危脆處境，手段可能例如讓仲介為虛偽之切結書付出相應的經濟或刑事代價、確保雇主負擔費用、乃至國對國引進排除私人仲介等。然而，臺灣在仰賴私人仲介業引進勞動力之餘，未能採取有效作為，降低移工為獲得跨國工作機會所負擔之債務佔收入之比例，而以無用的文書管理或刑事立法，搪塞外界對政府放任債務規模的指摘。就此臺灣政府還有長路須走。

(二) 勞動法令的欠缺

最後，臺灣移工制度明顯的缺失是，最需要勞動條件法令樓地板的經濟部門²⁸⁵，卻最缺乏法定勞動保護與法定勞工保險：家事勞動經勞動主管機關宣布為不適用勞動基準法之行業²⁸⁶，且不強制納

283 簡永達，(註274)，頁357。鄭智仁則指出勞力剝削類型的定罪率與性剝削相比偏低，檢察官起訴門檻與法院判決，二者對人口販運的勞動剝削認定有落差，鄭智仁(註276)，頁76。

284 簡永達分析2018-2020年的法院資料，發現臺灣各地法院申請本票裁定的前10名聲請人，有三家專門催討移工債務的財務公司。簡永達(註274)，頁357。

285 在家事移工外，另一個不適用勞動基準法的藍領移工類別是境外聘僱的漁工。勞動條件及就業平等司，漁船於境外僱用外籍漁工，其勞動權益之保障，依《遠洋漁業條例》授權訂定之「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」規範，勞動部，2017年1月17日，<https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1640/19846/post> [<https://perma.cc/X653-M223>]。相關批評參黃昱中，立意良善卻錯誤百出的外籍漁工聘僱雙軌制，全國律師，26卷4期，頁56-57(2022年)。但家事移工與境外聘僱漁工相比，法令保護密度更低，本文因此僅討論家戶移工。

286 勞動基準法第3條；行政院勞工委員會，(87)台勞動一字第059604號公告，<https://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDOC03.aspx?datatype=etype&N2=059604&cnt=1&mode=002&now=1&lnabndn=1&recordno=1> [<https://perma.cc/L2X8-PCKM>]。宣布「個人服務業中家事服務業之工作者」自1999年1月1日起不適用勞動基準法。值得注意的是，家事工作者在此公告之前，本是適用勞動基準法的。

入勞工保險²⁸⁷。其政策立場向來認為雇主為私人家戶，職場特性和事業單位不同，非生產性，納入勞動基準法將增加雇主負擔又無法轉嫁成本，窒礙難行云云²⁸⁸。

如果勞動基準法與家庭職場性質不符，那麼另訂更合用的保護規範似為正辦。惟民間數十年推動家事服務法²⁸⁹，政府亦回應有限。2014年馬政府之勞動部雖曾送出〈外籍家事勞工權益保障法草案〉²⁹⁰，但2017年第二次兩公約審查之結論性意見與回應，審查委員指出政府無心推動的實情：

自初次審查以來，包括仍舊排除適用勞動基準法的看護及幫傭工作者在內，外籍家事類勞工的處境幾無任何改變……再者，儘管2013年初次審查期間委員會曾表達嚴重關切，政府對多年來承諾制定的家事勞工保障法卻未採取任何行動²⁹¹。

審查委員要求，政府應於下次審查提出詳盡進度說明，及草案對移工的影響評估²⁹²。蔡政府之勞動部，在2020年第三次兩公約審查對上開意見的回應是，承認2011年迄今毫無進展，但辯稱並非毫

287 勞工保險條例第6條。

288 勞動條件及就業平等司，家事勞工納入《勞動基準法》予以保障，必須兼顧勞雇雙方權益與實務之可行性，勞動部，2014年6月19日，<https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1640/18849/> [<https://perma.cc/7A95-K4U4>]。

289 從2003年因劉俠事件所引發的家事服務法草案推動迄今已逾20年。顧玉玲，移工運動的主體形塑——以「家事服務法」推動過程為例，台灣社會研究季刊，74期，頁346（2009年）。

290 勞動力發展署，勞動部積極推動家事勞工保障法之立法，以保障家事勞工權益，勞動部，2014年3月9日，<https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1640/18494/> [<https://perma.cc/B5VJ-GLNZ>]。

291 兩公約第二次國家報告國際審查委員會，對中華民國（臺灣）政府關於落實國際人權公約第二次報告之審查：國際審查委員會通過的結論性意見與建議，2017年4月6日總統府人權諮詢委員會確認中文版，法務部，人權大步走 Human Right In Taiwan，31段，<https://www.humanrights.moj.gov.tw/media/12295/3552004141607ed2b9.pdf?mediaDL=true> [<https://perma.cc/YV7M-VVW6>]。

292 兩公約第二次國家報告國際審查委員會（註291），32段。

實則入境前締結書面契約、提供譯文與認證的要求，主要功能在避免境外招募的強迫與欺騙、契約遭掉包等²⁹⁴，這是古典意願模式對維護勞動自由的實踐，卻非避免剝削、確保整個行業勞動條件樓地板的足夠工具，否則書面、譯文、認證和制式條款，在產業移工亦有適用，難道產業移工因此不須再適用勞動基準法？契約尤因其意定性質、允許事後「基於外籍勞工本人自由意思」而為對勞工不利益之修改，如協議無薪休假²⁹⁵，且發生爭議時勞工須自力尋求救濟，欠缺行政奧援與主動介入²⁹⁶，不利於締約地位與尋求救濟能力較弱的移工。

所以勞動部以書面勞動契約存在，陳稱仍有勞動條件保護，是以意願模式保護自願性為核心的辯解，來回應能力模式對經濟危脆與箝制的關懷。過長工時與低薪都是強迫勞動或人口販運指標（剝削強指標），包括全日連續待命，沒有休息時間等。勞動部既稱合法家事移工契約已有約定工時工資，那麼保護效果如何呢？

296 傅柏翔，外籍家庭看護工重要勞動權利保障和救濟之多重困境分析——一個法與社會研究視角之初步反思，交大法學評論，勞動法特刊，頁146（2020年）。

工時上，以勞動部每年執行之〈外籍勞工管理及運用調查〉為例，因調查對象為雇主²⁹⁷，及問卷設計的侷限²⁹⁸，所計工時可能低估。儘管如此，2019年調查提要分析仍提及家戶移工的長工時性質：「由於外籍家庭看護工所照護者，多為需24小時照顧看護或是特定重度身心障礙者，因此外籍家庭看護工每日工作時間，雇主沒有規定者占81.4%」²⁹⁹。2022年調查平均每日工時約13小時³⁰⁰。

就休假來看，2019年（Covid-19疫情前）雇主陳述移工從無放假的比例約35%，2020年（疫情後）約42%、2021年約47%、2022年約50.6%。2022年雇主陳述從未放假原因（可複選，注意問卷設

297 以2019年為例，調查對象為受核准聘僱外籍移工之事業面及家庭面雇主。勞動部統計處，外籍勞工管理及運用調查實施計畫，勞動部，2019年，頁3，<https://statdb.mol.gov.tw/html/svy08/0842plan.pdf> [<https://perma.cc/V4EX-8XA7>]。

298 問卷設題方式暗示一日之工作時間會有早上起點與晚上終點，影響填答晚上連續待命與分散在24小時之內不間斷之工時。以2023年問卷家庭面調查表第14題為例：

請問您有沒有與外籍家庭看護工約定每日的工作時間？

☐ (1) 有規定，每日工作約自早上____點至晚上____點，期間用餐及休息時間共計____小時____分

☐ (2) 沒有規定，每日工作約自早上____點至晚上____點，期間用餐及休息時間共計____小時____分

勞動部統計處，勞動部移工管理及運用調查表，勞動部，2023年6月，<https://statdb.mol.gov.tw/html/s4/svy12/1242table.pdf> [<https://perma.cc/QYP4-LQUV>]。

299 勞動部，108年外籍勞工管理及運用調查報告，頁40（2019年）。

2019年「需要24小時看護」的陳述，在2020年的提要分析中改成「外籍家庭看護工所照護者，多屬特定重度身心障礙者或需長時間照顧看護者」，勞動部，109年移工管理及運用調查報告，頁30（2020年）。而2021年的提要分析中整段陳述都已刪除。勞動部，110年移工管理及運用調查報告，頁32（2021年）。就調查而言此一陳述確實未必恰當，因為問卷中並未問雇主無規定的原因為何。

300 勞動部（註257），頁31。調查針對家戶移工，除列出雇主所規定或所陳述之平均「工時」外，並列出「工作時間內休息時間」，二者相扣得出所謂平均「實際工作時間」，並於摘要中稱外籍家庭看護工「每日實際工作時間平均約10小時」。此種調查與陳述有混淆工時意義或刻意淡化總工時的沉重之嫌。縱使是「休息」，只要隨時處於雇主指揮監督、隨時可要求提供正常勞務的待命狀態下，仍舊是工時。參如臺灣高等法院高雄分院104年度勞上字第19號民事判決：「工作時間不僅包括勞工實際提供勞務之時間，亦應包括勞工係處於雇主得隨時指揮監督命令其提供勞務狀態之時間在內」。

計方式可能影響答案³⁰¹)，絕大多數勾選移工欲賺取加班費，歸給移工的自願；另有合計半數雇主所勾選的原因為疫情影響及無人手，這可能涉及違反自願。然即便移工是「自願」賺取加班費而不休假，薪資過低導致的過長工時本身亦是強迫勞動指標（前文「參、三、(一)、2.」）。不能下班也意謂家事移工24小時負擔職務義務，被照顧人發生意外時，在極端案例中有遭遺棄罪、傷害罪追訴之風險³⁰²。

就薪資部分，1997年之後，勞動主管機關令家事移工與基本工資脫鉤³⁰³，理由正是家事移工不適用勞動基準法³⁰⁴，其並以行政指導定型化契約方式，扼住家事移工薪資，表面是薪資下限，但現實則是薪資上限³⁰⁵，使其長達18年維持在1997年之基本工資15,840元³⁰⁶。2015年家事移工月薪上調至17,000、2022年調至20,000³⁰⁷，但僅適用於調薪生效後締約之移工。相較之下，受基本工資保障之

301 2023年版問卷家庭面調查表第12-1題：請問您目前所僱用的外籍家庭看護工平均每月放假幾次？[中略]

☐ (5)都不放假，都不放假的原因？（可複選）

☐ ①外籍家庭看護工想賺取加班費

☐ ②家中無替代照顧人力

☐ ③其他(請說明)_____（筆者按：2020-2022年疫情期間則列有「疫情影響」）

勞動部統計處（註298）。

302 黃姿華、劉梅君，黃姿華發言（註242），頁126。

303 台灣焦點通訊社，台灣的基本工資大事記，焦點事件，2023年9月8日，<https://eventsinfocus.org/issues/2546> [<https://perma.cc/E4AR-BFV2>]。

304 汪英達、劉黃麗娟，汪英達發言（註262），頁188。

305 傅柏翔（註296），頁145。

306 勞動條件及就業平等司，基本工資之制訂與調整經過，勞動部，2023年9月21日，<https://www.mol.gov.tw/1607/28162/28166/28180/28182/28184/29016/> [<https://perma.cc/XK6L-THCZ>]。

307 跨國勞動力管理組，自8月10日起新聘及續轉聘家事移工月薪調為2萬元 勞動部提供弱勢雇主薪資補貼配套最高10.8萬元，勞動部勞動力發展署，2022年8月10日，https://www.wda.gov.tw/News_Content.aspx?n=31&s=4149 [<https://perma.cc/Q5J2-X9HQ>]。

產業移工，2024年起月薪法定下限為27,470³⁰⁸，2023年產業移工平均月收3.2萬；家事移工平均月收2.3萬³⁰⁹。但勞動部甚至曾以家事移工在雇主家的食宿，亦是家事移工獲得之實物給付，辯護其低薪³¹⁰。姑不論這無異主張家事移工全時待命、無從逃離雇主指揮監督一事，也是移工所收到的「給付」，退萬步言，即便食宿是實物給付，此種給付方式仍是涉及剝削的低薪指標（前文「參、三、（一）、2.」）。

綜上，所謂「移工受契約保護」的託詞，無法取代法令樓地板，勞動部避免建立家事移工法定勞動標準，實際上有效壓抑家事移工的待遇，亦即成功降低雇主負擔，也削弱剝削之判定，與移工主張雇主違反勞動條件而轉職的法定基礎。建立勞動標準是能力模式中最基本而核心的要求，但臺灣就此之實踐，亦令人遺憾。

伍、結論

臺灣政府一直以來係將強迫勞動當作過時、不相干的問題。但事實上，強迫勞動在大量勞力跨國流動、與人口販運成為全球國境執法焦點之驅策下，不僅是熱度不減的棘手人權課題，移工更是反強迫勞動的重心。國際勞動遷徙可以促進區域發展與全球正義，但前提是，移工必須能進入良好管理、保護權利並顧及國內外勞工均衡的移工政策中³¹¹。臺灣作為受國際人權法拘束的移工輸入國，有

308 勞動條件及就業平等司（註306）。

309 勞動部，112年移工管理及運用調查報告，頁9、25（2023年）。

310 武陵，印尼政府：看護工要基本工資 勞動部：雇主包吃住算薪資，沃草 Watchout，2020年1月15日，<https://watchout.tw/reports/13a9w0bVsezRY39X0biH> [<https://perma.cc/52LB-QD59>]。

311 Daniel Costa & Philip Martin, *Temporary Labor Migration Programs: Governance, Migrant Worker Rights, and Recommendations for the U.N. Global Compact for Migration*, ECONOMIC POLICY INSTITUTE 2 (Aug. 1, 2018), <https://www.epi.org/>

絕對必要分析ILO C29實踐所帶出的國家義務範圍射程，本文是對這個任務的初步嘗試。未來研究進程，則可朝向細緻化義務類型，乃至尋求司法化的工具。

ILO C29近一世紀的軌跡，其焦點從殖民地到移工、從國家到私人、從非經濟性之強迫到經濟危脆所致的不自由。這樣的重心位移跨度很大，但不變的是強迫勞動作為一種生產體制，多麼常被施用在邊陲、不被視為政治共同體一分子的人群之上：過去的原住民、今日的移工。這個跨度也帶出了重要的理論問題，亦即國家應在多大範圍內、用什麼方式，介入處理受貧困與債務所趨策的勞動？又對於經濟危脆的關注，與強迫勞動傳統上限於非經濟性的不自由，彼此間的張力如何解決？

ILO對於這些問題的回應並不基進。它謹慎強調保護自願性的重要，要求對違犯者給予適切的刑事制裁、取消過度的轉職限制法令。對於經濟危脆的緩解，它強調健全的勞動法令與執法、避免因仲介費所生之債務等。這些措施卑之無甚高論，不是什麼「高級人權」，但臺灣移工制度的設計和實踐，卻在每一個面向都留下紅字，臺灣政府並反覆以契約意願來正當化移工的經濟箝制。可以說能力模式與意願模式對不自由勞動的認識落差，更加強了強迫勞動風險。當國家認真對待消除強迫勞動的任務，則必然深遠地衝擊暫時性移工制度的基本設計。

參考文獻

1. 中文部分

- 王正嘉（2013），勞動者保護與勞動刑法之法理與檢討，國立中正大學法學集刊，38期，頁99-148。
- 王皇玉（2017），人口販運與使人為奴隸罪，月旦刑事法評論，5期，頁5-20。
- 王韻茹（2019），從憲法觀點論移工權益的平等保障——以限制轉換雇主規定為例，法律扶助與社會，3期，頁1-16。
- 甘添貴（2019），刑法各論（上冊），5版，臺北：三民。
- 汪英達、劉黃麗娟（2020），與談紀錄，交大法學評論，勞動法特刊，頁187-194。
- 李建良（2014），論國際條約的國內法效力與法位階定序——國際條約與憲法解釋之關係的基礎課題，收於：廖福特編，憲法解釋之理論與實務第八輯（上冊），頁175-275，臺北：中央研究院法律學研究所。
- 法務部法制司編（2018），公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約：一般性意見，2版，臺北：法務部。
- 周琇環（2011），接運韓戰反共義士來臺之研究（1950-1954），國史館館刊，28期，頁115-154。
- 林良榮（2020），論外國人勞工（移工）團結權之行使與保護——ILO規範基礎、工會組織實務與團結政策，交大法學評論，勞動法特刊，頁233-270。
- 林佳和（計畫主持人）（2022），台灣產業移工管制與保障之比較研究，委託研究成果報告書，臺北：監察院。
- 邱羽凡（2023），移工制度研究進行式，過水有痕：「外勞」30年／MENT 20年國際研討會，台灣移工聯盟主辦，2023年12月16日。

- 邱羽凡、宋庭語（2020），移工自由轉換雇主之限制規範與檢討，
交大法學評論，勞動法特刊，頁1-50。
- 徐國淦（2014），從國際核心勞動基準探討我國勞動人權保障，台
灣勞工季刊，39期，頁6-23。
- 徐揮彥（2006），從高捷泰勞事件淺論禁止強迫勞動相關國際人權
規範之內涵及落實，台灣本土法學雜誌，83期，頁81-88。
- 高玉泉（2014），人口販運防制法之立法缺失與修法方向——以聯
合國相關規範為中心之檢視，台灣法學雜誌，246期，頁27-
38。
- 馬躍中（2013），我國勞動刑法的現狀與未來——兼論德國勞動刑
法，國立中正大學法學集刊，38期，頁149-182。
- 張文貞（2012），演進中的法：一般性意見作為國際人權公約的權
威解釋，台灣人權學刊，1卷2期，頁25-43。
- 郭明政（2007），社會法治國的司法建構——第六屆大法官會議有
關社會安全法制解釋之分析，憲政時代，33卷2期，頁187-
220。
- 陳炯志（2020），從臺韓移工聘僱歷史思索臺灣直接聘僱制度的改
善之道，交大法學評論，勞動法特刊，頁195-225。
- 陳菊、王幼玲、王美玉、紀惠容（2022），海上人權路，臺北：監
察院。
- 許恒達（2023），論合法／不作為惡害通知的可罰界限——以強制
罪、強制性交罪及恐嚇取財罪為中心，台灣法律人，25期，頁
2-32。
- 傅柏翔（2020），外籍家庭看護工重要勞動權利保障和救濟之多重
困境分析——一個法與社會研究視角之初步反思，交大法學評
論，勞動法特刊，頁133-175。
- 焦興鎧（2002），規範外籍勞工國際勞動基準之發展趨勢——兼論
對我國之影響，月旦法學雜誌，90期，頁205-221。
- （2004），全球化與基本勞動人權之保障，理論與政策，17

卷3期，頁77-102。

——（2007），工作平等國際勞動基準之建構，中華國際法與超國界法評論，3卷2期，頁367-417。

——（2009），國際勞動法之演進及最新發展趨勢，全國律師，13卷2期，頁4-25。

——（2017），國際勞動法之建構及發展，勞資關係論叢，19卷2期，頁1-38。

——（2019），國際勞工組織建構核心國際勞動基準之努力及對我國之啟示，台灣勞工季刊，58期，頁8-25。

黃姿華、劉梅君（2020），與談紀錄，交大法學評論，勞動法特刊，頁125-132。

黃昭元（1998），台灣與國際人權條約，新世紀智庫論壇，4期，頁42-50。

黃昱中（2022），立意良善卻錯誤百出的外籍漁工聘僱雙軌制，全國律師，26卷4期，頁55-60。

黃舒芃（2016），國際及區域人權公約在憲法解釋中扮演的角色，臺灣民主季刊，13卷1期，頁85-129。

黃源盛（2010），晚清民國刑法史料輯注（下冊），臺北：元照。

黃榮堅（1996），悲情姊妹花，月旦法學雜誌，10期，頁47-48。

楊雅雯（2021），跨越國境的勞動平權？——論勞動權利之平等保護面對「暫時性跨國移工制度」之侷限，中研院法學期刊，28期，頁211-285。

——（2024），台灣有遵守國際勞工組織核心公約之人權義務嗎？：整全人權法詮釋取徑之芻議，台灣人權學刊，7卷4期，頁5-28。

萬毓澤（2023），探尋人的本質：馬克思《巴黎手稿》、「能力取徑」與批判性社會科學，收於：何偉明編，重讀通識經典論文集（一）：馬克思《1844年經濟學哲學手稿》，頁69-122，香港：香港中文大學通識教育部。

廖福特(2011), 法院應否及如何適用《經濟社會文化權利國際公約》, 台灣人權學刊, 1卷1期, 頁3-25。

劉士豪、羅國應(2010), 批准「兩公約」對我國勞動法制之影響——論其與ILO公約及建議書之關係, 台灣國際法季刊, 7卷4期, 頁5-46。

劉梅君(2000), 「廉價外勞」論述的政治經濟學批判, 台灣社會研究季刊, 38期, 頁59-90。

蔡明學、劉黃麗娟(2020), 與談紀錄, 交大法學評論, 勞動法特刊, 頁85-91。

鄭智仁(2017), 人口販運之判決分析——以地方法院判決為例, 亞洲家庭暴力與性侵害期刊, 13卷1期, 頁53-86。

謝開平(2009), 檢視我國販賣人口刑罰規定之演進, 成大法學, 18期, 頁39-101。

藍佩嘉(2006), 合法的奴工, 法外的自由: 外籍勞工的控制與出走, 台灣社會研究季刊, 64期, 頁107-150。

藍佩嘉、簡永達(2022), 越南牛頭與台灣仲介: 跨國招工網絡的彈性重組, 台灣社會學, 43期, 頁1-50。

簡永達(2023), 移工築起的地下社會: 跨國勞動在臺灣, 臺北: 春山出版。

羅國榮(2017), 由國際發展觀點論人口販運勞力剝削之刑事規範, 國立中正大學法學集刊, 56期, 頁19-98。

顧玉玲(2009), 移工運動的主體形塑——以「家事服務法」推動過程為例, 台灣社會研究季刊, 74期, 頁343-365。

——(2013), 跛腳的偽自由市場: 檢析台灣外勞政策的三大矛盾, 台灣人權學刊, 2卷2期, 頁93-112。

2. 外文部分

van Alphen Fyfe, Monique, and Guy Fiti Sinclair. 2020. Supervisory and Review Procedures: International Labour Organization (ILO). In

Max Planck Encyclopedias of International Law, <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-mpeipro/e1617.013.1617/law-mpeipro-e1617>.

- Anderson, Bridget, and Ben Rogaly. 2005. Forced Labour and Migration to the UK. In *COMPAS, University of Oxford*, https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/PR-2007-Forced_Labour_TUC.pdf.
- Andrees, Beate, and Amanda Aikman. 2017. Raising the Bar: The Adoption of New ILO Standards against Forced Labour. Pp. 359-394 in *Revisiting the Law and Governance of Trafficking, Forced Labor and Modern Slavery*, edited by Prabha Kotiswaran. Cambridge: Cambridge University Press.
- Arneson, Richard. 2013. Egalitarianism. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Summer 2013 ed., edited by Edward N. Zalta, <https://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/egalitarianism/>.
- Banaji, Jairus. 2003. The Fictions of Free Labour: Contract, Coercion, and So-Called Unfree Labour. *Historical Materialism* 11(3):69-95.
- Baruah, Nilim, Heike Lautenschlager, and PE Research. 2018. *Worker-Paid Migration Costs in the Viet Nam-Malaysia Corridor*. Bangkok: ILO Regional Office for Asia and the Pacific. http://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_657134/lang--en/index.htm.
- Berlin, Isaiah. 2002. *Liberty*, 2d ed., edited by Henry Hardy. Oxford: Oxford University Press.
- Bernards, Nick. 2017. The Global Politics of Forced Labour. *Globalizations* 14:944-957.
- Brass, Tom. 1994. Some Observations on Unfree Labour, Capitalist Restructuring, and Deproletarianization. *International Review of Social History* 39:255-275.
- . 1999. *Towards a Comparative Political Economy of Unfree Labour: Case Studies and Debates*. London: Routledge.

- Dalton, Clare. 1985. An Essay in the Deconstruction of Contract Doctrine. *The Yale Law Journal* 94:997-1114.
- Davidov, Guy. 2016. *A Purposive Approach to Labour Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Davidson, Julia O'Connell. 2010. New Slavery, Old Binaries: Human Trafficking and the Borders of 'Freedom'. *Global Networks* 10:244-261.
- Dawson, John P. 1947. Economic Duress: An Essay in Perspective. *Michigan Law Review* 45:253-290.
- Fudge, Judy. 2018. Modern Slavery, Unfree Labour and the Labour Market: The Social Dynamics of Legal Characterization. *Social & Legal Studies* 27:414-434.
- . 2019. (Re)Conceptualising Unfree Labour: Local Labour Control Regimes and Constraints on Workers' Freedoms. *Global Labour Journal* 10:108-122.
- Gallagher, Anne T. 2010. *The International Law of Human Trafficking*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hurd, Ian. 2020. *International Organizations: Politics, Law, Practice*. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- ILO. 1979. *Abolition of Forced Labour: General Survey Concerning the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)*. Geneva: ILO.
- . 2005. *A Global Alliance against Forced Labour: Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 2005*. Geneva: ILO. http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_081882/lang--en/index.htm.
- . 2007. *Eradication of Forced Labour: General Survey Concerning the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and the*

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105). Geneva: ILO.

- . 2015. *Combating Forced Labour: A Handbook for Employers and Business*. Geneva: ILO. http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm.
- . 2019. *General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment and Definition of Recruitment Fees and Related Costs*. Geneva: ILO. http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_536755/lang--en/index.htm.
- . 2019. *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, ILC.108/III(A)*. Geneva: ILO. https://ilo.primo.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/41ILO_INS T:41ILO_V2/1258339380002676.
- . 2020. *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, ILC 109/III(A)*. Geneva: ILO. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_736204.pdf.
- . 2021. *Addendum to the 2020 Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, ILC.109/III/Add.(A)*. Geneva: ILO. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_771042.pdf.
- . 2022. *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, ILC.110/III(A)*. Geneva: ILO. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836653.pdf.
- . 2023. *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, ILC 111/III(A)*. Geneva: ILO. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/

documents/meetingdocument/wcms_868115.pdf.

ILO, Walk Free, and International Organization for Migration. 2022. *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*. Geneva: ILO, Walk Free, and International Organization for Migration.

International Labour Office. 2012. *Hard to See, Harder to Count: Survey Guidelines to Estimate Forced Labour of Adults and Children*. 2d ed. Geneva: ILO.

Koettl, Johannes. 2009. Human Trafficking, Modern Day Slavery, and Economic Exploitation. Working Paper. Soc. Protection Discussion Papers, Paper No. 0911. Available at <https://documents1.worldbank.org/curated/en/208471468174880847/pdf/498020NWP0SP0d10Box341969B01PUBLIC1.pdf>.

Langille, Brian A. 2009. What Is International Labour Law For?. *Law & Ethics of Human Rights* 3:47-82.

LeBaron, Genevieve. 2015. Unfree Labour Beyond Binaries: Insecurity, Social Hierarchy and Labour Market Restructuring. *International Feminist Journal of Politics* 17:1-19.

Lerche, Jens. 2007. A Global Alliance Against Forced Labour? Unfree Labour, Neo-Liberal Globalization and the International Labour Organization. *Journal of Agrarian Change* 7:425-452.

Martineau, Anne-Charlotte. 2019. Forced Labour. Pp. 271-286 in *International Law and the Cold War*, edited by Matthew Craven, Sundhya Pahuja and Gerry Simpson. Cambridge: Cambridge University Press.

Marx, Karl. 1976. *Capital: A Critique of Political Economy Vol. I*, translated by Ben Fowkes. London: Penguin Books.

Maul, Daniel Roger. 2007. The International Labour Organization and the Struggle against Forced Labour from 1919 to the Present.

- Labour History* 48:477-500.
- O'Neill, John. 2022. Varieties of Unfreedom. In *The University of Manchester Research*, <https://research.manchester.ac.uk/en/publications/varieties-of-unfreedom>.
- Patterson, Orlando. 1982. *Slavery and Social Death: A Comparative Study*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Payandeh, Mehrdad. 2015. Fragmentation within International Human Rights Law. Pp. 297-319 in *A Farewell to Fragmentation: Reassertion and Convergence in International Law*, edited by Mads Andenas and Eirik Bjorge. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pettit, Philip. 2003. Agency-Freedom and Option-Freedom. *Journal of Theoretical Politics* 15:387-403.
- Premchander, Smita, V. Prameela, and M. Chidambaranathan. 2014. *Prevention and Elimination of Bonded Labour: The Potential and Limits of Microfinance-Led Approaches*. Geneva: ILO. https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_334875/lang--en/index.htm.
- Rao, J. Mohan. 1999. Freedom, Equality, Property and Bentham: The Debate over Unfree Labour. *The Journal of Peasant Studies* 27(1):97-127.
- Robeyns, Ingrid. 2017. *Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined*. Cambridge: Open Book Publishers.
- Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. New York, NY: Alfred A. Knopf.
- . 2002. *Rationality and Freedom*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Shamir, Hila. 2017. The Paradox of “Legality”: Temporary Migrant Worker Programs and Vulnerability to Trafficking. Pp. 471-502 in *Revisiting the Law and Governance of Trafficking, Forced Labor*

- and Modern Slavery*, edited by Prabha Kotiswaran. Cambridge: Cambridge University Press.
- Skrivankova, Klara. 2010. *Between Decent Work and Forced Labour: Examining the Continuum of Exploitation*. York: Joseph Rowntree Foundation. <https://resourcecentre.savethechildren.net/document/between-decent-work-and-forced-labour-examining-continuum-exploitation/>.
- Steinfeld, Robert. 2009. Coercion/Consent in Labour, Working Paper. Centre on Migration, University of Oxford. Policy and Society Working Paper No. 66. Available at https://www.compas.ox.ac.uk/2009/wp-2009-066-steinfeld_coercion_consent_labour/.
- Stone, Katherine V.W. 2007. Revisiting the At-Will Employment Doctrine: Imposed Terms, Implied Terms, and the Normative World of the Workplace. *Industrial Law Journal* 36:84-101.
- Strauss, Kendra. 2012. Coerced, Forced and Unfree Labour: Geographies of Exploitation in Contemporary Labour Markets. *Geography Compass* 6:137-148.
- Sweptston, Lee. 2015. *Forced and Compulsory Labour in International Human Rights Law*. Geneva: ILO.
- . 2017. Trafficking and Forced Labour: Filling in the Gaps with the Adoption of the Supplementary ILO Standards, 2014. Pp. 395-421 in *Revisiting the Law and Governance of Trafficking, Forced Labor and Modern Slavery*, edited by Prabha Kotiswaran. Cambridge: Cambridge University Press.
- . 2019. How the ILO Embraced Human Rights. Pp. 295-313 in *Research Handbook on Labour, Business and Human Rights Law*, edited by Janice Bellace and Beryl ter Haar. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Tennant, Ian. 2021. Fulfilling the Promise of Palermo? A Political

History of the UN Convention Against Transnational Organized Crime. *Journal of Illicit Economies and Development* 2:53-71.

Wolff, Jonathan. 2018. Structures of Exploitation. Pp. 175-187 in *Philosophical Foundations of Labour Law*, edited by Hugh Collins, Gillian Lester and Virginia Mantouvalou. New York, NY: Oxford University Press.

Zwolinski, Matt, Benjamin Ferguson, and Alan Wertheimer. 2022. Exploitation. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Winter 2022 ed., edited by Edward N. Zalta and Uri Nodelman, <https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/exploitation/>.

Does Taiwan's Temporary Migrant Workers Scheme Lead to Forced Labour?:

Assessing Taiwan's Human Rights Performance against ILO Practices and Two Conceptions of Unfree Labour

*Ya-Wen Yang**

Abstract

Does Taiwan's low-skilled temporary migrant workers (TMWs) scheme lead to forced labour? This paper argues that it likely does. The significance of this inquiry cannot be overemphasised. If the TMWs scheme were a forced labour institution supported by state law, not only would the state have committed systematic human rights violations, but employers would also be involved in offences related to forced labour and human trafficking. Taiwan's supply chains might face sanctions from trading partners.

This article investigates Taiwan's TMWs scheme in light of the practice and interpretation under Convention 29 (C29) of the International Labour Organization (ILO). It first points out that ILO C29 has normative force upon Taiwan, even if Taiwan is not allowed to be an ILO member, because C29 has constituted part of the state's human rights obligations under Article 6 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Second, this paper proposes two conceptions of unfree labour—the voluntariness model and the capabilities model—as the analytical framework to understand ILO's trace to eliminate forced labour. While the voluntariness model only considers non-economic coercion as unfree labour, the capabilities model expands the conception to include economic vulnerability. This

* Assistant Research Professor, Institutum Iurisprudentiae, Academia Sinica.

article highlights that the ILO's focus has shifted from the voluntariness model towards the capabilities model, from preventing non-economic coercion towards eliminating exploitative working conditions and economic vulnerability. Finally, this article measures Taiwan's TMWs scheme against practices under C29. It points out that the government tends to respond to the requirements of the capabilities model with the rhetoric of the voluntariness model. The result is insufficient penalties for forced labour offences, exceeding limitations on migrant workers' freedom to change jobs, absence of legal labour standards, and institutional justification for migrant workers' plight in debt bondage. To sum up, the forced labour risks of Taiwan's TMWs scheme reflect the gap between how forced labour should be eliminated under the voluntariness model and capacities model.

KEYWORDS: forced labour, unfree labour, human trafficking, modern slavery, migrant workers, International Labor Organization (ILO), Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), labour rights, debt bondage, capabilities approach.